

성과상여금의 (평균)임금성

[Whether Performance Bonus Constitutes (Average)
Wages]

임 상 민(Lim Sang-min)

부산고등법원 고법판사

요 지

대법원이 최근 공기업 집단성과상여금(경영평가성과급)의 (평균)임금성을 인정하는 판결들을 선고한 이후, 사기업 집단성과상여금의 (평균)임금성에 대한 논의가 활발해졌다.

사용자가 근로자에게 지급하는 성과상여금의 임금성에 대한 선행판결들을 보면 문제점이 있다. 임금성과 평균임금성을 준별하지 않고 있다. 근로의 대가 인지, 근로계약 등에 의한 지급의무가 인정되는지 여부만이 임금의 요건이다. 대법원이 중시하는 지급의 계속·정기성이나 지급사유의 사전확정성은 평균임금에서 제외되는 임시로 지급되는 임금을 판단하는 요소라 할 것이다.

개인성과상여금의 임금성을 인정하는 것이 주류적인 선행판례의 태도인 데 타당하다고 생각한다. 공기업 집단성과상여금의 평균임금성을 인정한 선행판례들은 집단성과상여금이 근로의 대가임을 전제로 한다. 타당하다고 생각한다. 그렇다면 사기업 집단성과상여금도 근로의 대가인 임금에 해당한다고 보아야 할 것이다.

임금성을 인정하더라도 평균임금성이 있는지는 더 따져보아야 한다. 평균임금의 판단요소인 지급의 계속·정기성과 지급사유의 사전확정성이 어떤 관계에 있는지도 문제이다. 둘 중 어느 하나만 인정되더라도 임시로 지급되는 임금이라고 볼 수는 없으므로 평균임금에 해당한다고 보아야 할 것이다.

주제어: 임금, 평균임금, 임시로 지급되는 임금, 근로의 대가, 지급의무, 지급의 계속·정기성, 지급사유의 사전확정성, 성과상여금, 개인성과상여금, 집단성과상여금, 경영평가성과급, 근로자, 사용자 등

◆논문접수: 2021. 1. 18. ◆심사개시: 2021. 1. 25. ◆게재확정: 2021. 2. 17.

성과상여금의 (평균)임금성*

임 상 민

I. 문제의 제기

사용자가 근로자에게 지급하는 금품 중 어떤 항목이 임금, 평균임금, 통상임금 등에 해당하는지가 꾸준히 소송에서 다투어지고 있다. 대법원 2012다89399 전원합의체 판결이 재직조건이 붙은 정기상여금의 통상임금성을 부정하였으나 학설로부터 많은 비판을 받았고,¹⁾ 최근 재직조건 자체가 무효라고 판시한 하급심판결²⁾에 대한 상고가 제기되어 대법원 전원합의체에서 다시 검토 중인 것처럼, 주로는 고정성 등 문제 되는 항목의 통상임금성이 다투어져 왔다.

그런데 2018. 12.에 공기업 집단성과상여금(경영평가성과급)의 (평균)임금성을 인정한 판결들³⁾이 잇따라 선고되면서 성과상여금의 임금성에 대한 학계의 논의를 촉발하였고,⁴⁾ 위 판결들의 영향으로 짐작되는 데 최근 사기업 집단성과상여금의 임금성을 다투는 사건이 부쩍 늘어났으며, 그중에는 이미 제1심판결이 선고되어 항소 중인 사건도 있다.⁵⁾

* <https://doi.org/10.22825/juris.2021.1.55.023>

1) 노동법실무연구회(최은배 집필 부분), 근로기준법 주해 I 2판, 박영사(2020), 323~330.

2) 서울고법 2018. 12. 18. 선고 2017나2025282 판결(상고되어 대법원 2019다204876호 사건으로 전원합의체 검토 중). 부산고법 2019. 9. 18. 선고 2018나55282 판결도 같은 취지로 선고하여 대법원 2019다289525호 사건으로 검토).

3) 대법원 2018. 10. 12. 선고 2015두36157 판결(한국감정원 사건), 대법원 2018. 12. 13. 선고 2018다231536 판결(한국공항공사 사건), 대법원 2018. 12. 28. 선고 2016다239680 판결(주택도시보증공사 사건), 대법원 2018. 12. 28. 선고 2018다219123 판결(한국산업인력공단 사건) 등.

4) 권오성, “경영 성과급의 임금성”, 노동법률 통권 346호, 중앙경제사(2020); 박지순·이진규, “경영성과급의 임금성에 관한 연구”, 노동법논총 49집, 한국비교법학회(2020); 심재진, “공공기관 경영평가성과급의 임금성”, 산업관계연구 29권 3호, 한국고용노사관계학회(2019); 유성재, “경영평가성과급의 임금성”, 노동법률 통권 343호, 중앙경제사(2019); 정종철, “변동성과급은 평균임금에 포함되어야 하는가?”, 노동법률 통권 340호, 중앙경제사(2019) 등.

5) SK하이닉스 사건에서 임금성을 부정하는 취지의 판결이 선고되었고(수원지법 여주지원 2020. 1. 21. 선고 2019가단50590 판결, 항소기각), 삼성전자 사건에서도 임금성을 부정하는 취지의 판결이 선고

이러한 현실을 고려하면 개인성과상여금과 사기업 및 공기업의 집단성과상여금 모두에 관하여 임금성(평균임금성)이 있는지를 통일적으로 검토할 필요가 있다.

이하에서는 이러한 논의의 법리적 전제가 되는 임금의 요건과 ‘근로의 대상’의 의미를 먼저 살펴본 후, 개인성과상여금의 임금성, 집단성과상여금의 임금성 순으로 선행판례를 소개하고 그 당부를 검토하고, 실무상 문제 되는 영역을 정리하면서 결론을 내리고자 한다.

II. 임금의 요건과 근로의 대가

1. 임금의 요건

대법원은 다수의 판결에서 근로의 대가, 지급의 계속성·정기성, 근로계약 등에 의한 지급의무의 존재를 임금의 요건으로 파악하는 듯 판시를 하면서,⁶⁾ 지급의무의 근거로 근로계약, 단체협약, 취업규칙 등과 함께 사용자의 방침이나 노동관행도 들고 있다.⁷⁾

대법원은 또한 근로의 대가(대상)만을 임금의 요건으로 파악하면서, 지급의 계속성·정기성(일부 판결은 일률성까지 들고 있기도 하다), 지급의무의 존재를 근로의 대가를 판단하는 징표(요소)라고 판시하기도 하고,⁸⁾ 지급여부(또는 지급액)

되었다(수원지법 2020. 11. 26. 선고 2019가합19095 판결, 현재 수원고법 2020나26085호 사건으로 항소심 계속 중임). 그 외에 삼성디스플레이, 삼성카드, LG디스플레이 등도 현재 제1심 소송이 진행 중이라고 한다(<https://blog.naver.com/yhjean/221780848317>) 참조.

6) 임금이라 함은 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 지급하는 일체의 금원으로서, 근로자에게 계속적·정기적으로 지급되고 그 지급에 관하여 단체협약, 취업규칙 등에 의하여 사용자에게 지급의무가 지워져 있다면, 그 명칭 여하를 불문하고 모두 그에 포함된다(대법원 1999. 9. 3. 선고 98다34393 판결, 대법원 2005. 9. 9. 선고 2004다41217 판결, 대법원 2012. 2. 9. 선고 2011다20034 판결 등).

7) 대법원 2012. 2. 9. 선고 2011다20034 판결 등.

8) 어떤 금품이 임금에 해당하는지 여부를 가늠할 수 있는 구체적인 사정으로서, 근로자에게 계속적·정기적으로 지급되며, 그 지급에 관하여 단체협약, 취업규칙, 급여규정, 근로계약, 노동관행 등에 의하여 사용자에게 그 지급의무가 지워져 있고, 또한 일정 요건에 해당하는 근로자에게 일률적으로 지급하는 것이라면, 그 명칭 여하를 불문하고 우선적으로 임금이라고 볼 수 있을 것이다(대법원 1990. 12. 7. 선고 90다카19647 판결, 대법원 2002. 10. 17. 선고 2002다8025 전원합의체 판결, 대법원 2003. 4. 22. 선고 2003다10650 판결 등 참조). 그러나 위와 같은 사정들은 어디까지나 근로의 대상으로 지급되는 금품으로 인정할 수 있는 대표적인 징표로 삼을 수 있다는 것이고, 위와 같은 사정을 갖춘 경우에 한해서만 임금에 포함시킬 수 있다는 의미는 아니다. 이와 같이 볼 때, 사용자가 근로자에게 지급하는 임금은 계속적·정기적으로 지급되는 것이 통상적이므로 그 지급사유의 발생이 확정되어 있지 않고 일시적으로 지급되는 것은 근로의 제공과 관련 없이 지급되는 것으로 판단받을 여지가 많기는

의 불확정성과 지급의 계속성·정기성으로 근로의 대가인 임금 여부를 판단하기도 한다.⁹⁾

한편 근로기준법 제2조 제1항 제4호는 ‘근로자가 사용자에게 근로를 제공하고 사용자는 이에 대하여 임금을 지급하는 것을 목적으로 체결한 계약’을 근로계약으로 정의하고, 같은 항 제5호는 ‘사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 모든 금품’으로 임금을 정의한다.

위 정의규정에 의하면, ① 근로의 대가, ② 근로계약 등에 따른 지급의무 두 가지가 임금의 요건이라고 말할 수 있다.¹⁰⁾ 물론 근로기준법 제2조 제1항 제5호는 근로의 대가를 임금이라고 정의하고 있으므로 ‘근로의 대가’만으로 임금을 정의하여야 한다고도 생각할 수 있지만,¹¹⁾ 근로제공의무와 임금지급의무는 근로계약에 의하여 쌍무적으로 발생하는 의무이므로, 근로계약에 의한 지급의무 또한 임금의 요건이라고 함이 타당할 것이다.¹²⁾ 다만 근로기준법 제15조, 제97조, 노동조합 및 노동관계조정법 제33조 등은 근로기준법 등 법령, 단체협약, 취업규칙 등에 의하

하지만(대법원 1999. 9. 3. 선고 98다34393 판결, 대법원 2002. 6. 11. 선고 2001다16722 판결 등 참조), 그렇다고 하여 반드시 계속적·정기적으로 지급되어야만 근로제공과 관련된 것이고 그렇지 않은 것은 근로제공과 무관한 것이라는 논리필연적인 관계가 있는 것은 아니므로, 드물게나마 계속적·정기적으로 지급되는 것이 아니라 하더라도 다른 사정을 종합하여 사용자가 근로자의 근로제공과 관련하여 지급하는 것으로 볼 수 있으면 임금에 해당하고, 이와 달리 어느 금품이 계속적·정기적으로 지급되는 것이라 하더라도 근로의 제공과 관련 없이 지급되는 것이라면 그 금품의 지급이 단체협약, 취업규칙, 근로계약 등에 의하여 지급의무가 발생한 것이라 하더라도 임금에 포함시킬 수 없을 것이다(대법원 2006. 8. 24. 선고 2004다35052 판결).

9) 상여금이 계속적·정기적으로 지급되고 그 지급액이 확정되어 있다면 이는 근로의 대가로 지급되는 임금의 성질을 가지나, 그 지급사유의 발생이 불확정이고 일시적으로 지급되는 것은 임금이라고 볼 수 없으며, 또한 그 상여금이 퇴직금 산정의 기초가 되는 평균임금에 산입될 수 있는지의 여부는 특별한 사정이 없는 한 퇴직 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 5. 26. 선고 2003다54322, 54339 판결).

10) 제3자가 아닌 사용자에게 의한 지급을 독자적 요건으로 보는 견해도 있다(이상훈, 노동법 16판, 법문사(2019), 196).

11) 권오성(주 4), 66. 위 논문의 전체적인 취지는 근로계약 등에 의한 근로의무의 존재를 ‘근로의 대가’를 판단하는 요건으로 보고 있는 듯한데, 그렇다면 실질적으로는 필자와 견해를 같이 하는 것이 아닌가 생각한다. 다만 객관적으로 근로의 대가(대상)인지 여부와 근로계약 등에 의하여 지급의무가 근거 지워져 있는지는 개념적으로 구별될 수 있다고 생각하여 본문에서는 임금의 요건을 두 가지로 나누었다.

12) 대법원 1973. 3. 27. 선고 72다2425 판결(“교재연구비의 성격이 근로의 대상인지 또는 의례적 또는 호의적인 데 불과한 지급인지의 여부는 원심판결이 위 열거한 사실만으로는 확정하기 곤란하고 모름지기 교재연구비의 지급이 반드시 명시적은 아니어도 근로계약상의 내용으로서 의무적으로 지급되는지의 여부에 따라 결정되어야 할 것으로서...”도 같은 취지로 이해된다.

여도 일정한 범위에서 근로계약의 내용을 보충, 수정하고 있으므로, 임금지급의무의 내용은 법령, 단체협약, 취업규칙 등에 의해서도 정해질 수 있다. 예컨대, 시간외수당에 대하여 사용자가 근로자와 근로계약으로 아무런 약정을 하지 않더라도, 사용자는 근로기준법 제56조가 정한 바에 따라 통상임금에 따른 가산임금을 지급하여야 하는데, 이와 같이 지급되는 가산임금은 비록 근로계약에서 정한 바가 없더라도 당연히 임금에 해당한다. 대법원은 사용자의 방침이나 노동관행도 지급의무의 근거로 인정한다.¹³⁾ 다만 노사 간에 그 지급이 당연한 것으로 여겨질 정도의 관례가 형성된 경우라면 노동관행의 존재를 인정할 수 있다.¹⁴⁾ 한편 사용자에게 지급의무가 있다는 의미는 그 지급 여부를 사용자가 임의로 결정할 수 없음을 의미한다.¹⁵⁾

2. 근로의 대가(대상)

그렇다면 임금 요건인 ‘근로의 대가’란 무엇인가? 근로의 대가란 근로계약에 따라 근로자가 사용자의 지시 감독을 받으며 제공하였거나 제공할 근로에 대한 보수라고 이해된다.¹⁶⁾

대법원은 금품지급의무의 발생이 근로제공과 직접적으로 관련되거나 그것과 밀접하게 관련된 경우에 ‘근로의 대가’성을 인정한다.¹⁷⁾ 한편 지급의무 없이 의례

13) 사용자에게 근로의 대상성이 있는 금품에 대하여 그 지급의무가 있다는 것은 그 지급 여부를 사용자가 임의적으로 결정할 수 없다는 것을 의미하는 것이고, 그 지급의무의 발생근거는 단체협약이나 취업규칙, 급여규정, 근로계약에 의한 것이든 그 금품의 지급이 사용자의 방침이나, 관행에 따라 계속적으로 이루어져 노사 간에 그 지급이 당연한 것으로 여겨질 정도의 관례가 형성된 경우처럼 노동관행에 의한 것이든 무방하다(대법원 1997. 5. 28. 선고 96누15084 판결, 대법원 2001. 10. 23. 선고 2001다53950 판결, 대법원 2020. 4. 9. 선고 2015다54523 판결 등).

14) 개인적으로는 사용자의 방침이나 노동관행을 독립적 지급의무로 인정하는 것이 타당한지 의문이 있다. 왜냐하면 단체협약, 취업규칙 등과 달리 사용자의 방침이나 노동관행은 그 자체로는 법령에 의하여 인정되는 임금 요건이 아니기 때문이다. 사용자의 방침이나 노동관행 등이 있는 경우에는 묵시적 근로계약 등의 존재를 인정함으로써 임금 요건을 인정하여 같은 결론을 내리는 것이 타당하지 않나 생각한다.

15) 대법원 1997. 5. 28. 선고 96누15084 판결, 대법원 2001. 10. 23. 선고 2001다53950 판결, 대법원 2020. 4. 9. 선고 2015다54523 판결 등. 강기탁, “상품권 판매에 따른 개인포상금이 퇴직금 산정의 기초가 되는 평균임금에 포함되는지 여부”, 노동관계 비평, 민주사회를 위한 변호사모임(2003), 204; 김유성, 노동법 I - 개별적 근로관계법, 법문사(2005), 78.

16) 김형배, 노동법 26판, 박영사(2018), 351; 하경호, 임금법제론, 신조사(2013), 25.

17) 대법원 2019. 8. 22. 선고 2016다48785 전원합의체 판결. 근로제공과의 ‘밀접성’ 여부로 임금성을 판단할 것이 아니라, 근로제공과 ‘포괄적’ 관련성이 있으면 근로의 대가로서 임금성을 인정해야 한다

적·호의적 의미에서 지급되는 것¹⁸⁾과 특수한 근로조건이나 환경에서 직무를 수행하게 됨으로 말미암아 추가로 소요되는 비용을 변상하기 위하여 지급되는 실비 변상적인 것¹⁹⁾은 근로의 대가가 아니라고 보아 임금성을 부정한다.

추상적으로는 근로의 대가를 위와 같이 설명할 수 있으나 사용자가 지급하는 특정 금품이 근로의 대가인지를 판단하는 것이 용이하지만은 않다. 근로의 대가 여부를 판단할 때에는 다음과 같은 점들을 고려하여야 할 것이다.

가. 임금2분설의 폐기

대법원은 종래에 근로의 대가인 임금(교환적 부분)과 근로자의 지위에서 받는 임금(생활보장적 부분)으로 임금을 2분하여 법적 효과를 달리 취급하였다. 즉 정의행위 중이라도 교환적 부분인 임금에만 무노동 무임금 원칙이 관철되므로 생활보장적 부분인 임금은 지급되어야 한다고 보았고, 생활보장적 임금의 대표적인 사례로 가족수당, 주택수당 등을 들고 있었다. 그러나 대법원은 1995. 12. 21. 선고 94다26721 전원합의체 판결로 종래의 임금2분설을 폐기하고, 모든 임금은 근로의 대가라고 판시하였다.²⁰⁾ 위 전원합의체 판결을 언뜻 보면, 임금2분설에서 말하는

는 견해도 있다. 김태욱, “개인실적에 따라 지급되는 성과금의 임금성”, 노동판례 비평, 민주사회를 위한 변호사모임(2012), 220; 김기선, “개인 실적에 따라 지급되는 성과금의 임금성”, 노동법률 통권 280호, 중앙경제사(2014), 81.

18) 대법원 1976. 1. 27. 선고 74다1580 판결, 대법원 2006. 2. 23. 선고 2005다53996 판결 등. 결혼축의금, 조의금, 상병위로금 등 경조금이 대표적인 사례이다. 김홍영, “근로자 개인의 실적에 따라 결정되는 성과급 상여금의 임금성 여부”, 노동법률 158호, 중앙경제사(2004), 231.

19) 대법원 1990. 11. 9. 선고 90다카4683 판결, 대법원 1995. 3. 28. 선고 94다37639 판결, 대법원 2003. 4. 22. 선고 2003다10650 판결 등.

20) 근로기준법 제17조, 제18조, 민법 제656조 제2항, 의료보험법 제3조 등 현행 실정법하에서는, 모든 임금은 근로의 대가로서 ‘근로자가 사용자의 지휘를 받으며 근로를 제공하는 것에 대한 보수’를 의미하므로 현실의 근로제공을 전제로 하지 않고 단순히 근로자로서의 지위에 기하여 발생하는 이른바 생활보장적 임금이란 있을 수 없고, 또한 우리 현행법상 임금을 사실상 근로를 제공한 데 대하여 지급받는 교환적 부분과 근로자로서의 지위에 기하여 받는 생활보장적 부분으로 2분할 아무런 법적 근거도 없다. 뿐만 아니라 임금의 지급 실태를 보더라도 임금은 기본적으로 근로자가 생활하는 데 필요한 생계비와 기업의 지불능력과 상관관계에 따라 형성되는 데 임금을 지불항목이나 성질에 따라 사실상 근로를 제공한 데 대하여 지급받는 교환적 부분과 현실의 근로제공과는 무관하게 단순히 근로자로서의 지위에 기하여 받는 생활보장적 부분으로 나누고(이른바 임금2분설) 이에 따라 법적 취급을 달리하는 것이 반드시 타당하다고 할 수도 없고, 실제로 현실의 임금 항목 모두를 교환적 부분과 생활보장적 부분으로 준별하는 것은 경우에 따라 불가능할 수 있으며, 임금2분설에서 전형적으로 생활보장적 임금이라고 설명하는 가족수당, 주택수당 등도 그 지급 내용을 보면 그것이 근로 시간에 직접 또는 비례적으로 대응하지 않는다는 의미에서 근로제공과의 밀접도가 약하기는 하지만

교환적 부분만 임금이고, 생활보장적 부분은 더 이상 임금이 아니라는 식으로 오해될 수 있다. 그러나 위 전원합의체 판결의 취지는, 임금2분설에서 말하는 생활보장적 임금이라는 것도 임금2분설에서 말하는 근로의 대가 부분과 비교할 때 상대적으로 근로제공과의 밀접도가 약할지는 몰라도 여전히 근로제공의 대가로 평가되므로(설령 근로제공의 ‘직접적’ 대가가 아니라 하더라도 근로제공과 밀접한 관계를 가지므로) 근로의 대가인 임금에 해당한다는 것이다. 즉, 종래 근로자의 지위에서 받는 임금(생활보장적 부분)도 근로의 대가성이 인정된다. 다만 종래 생활보장적 임금도 근로의 대가이므로 쟁의행위 중에는 무노동 무임금 원칙에 따라 그 지급의무가 부정될 뿐이다.

나. 근로계약에 따른 지급

근로계약에 따른 근로자의 의무는 근로제공이고 사용자의 의무는 임금지급이며 두 의무는 쌍무·유상의 관계에 있으므로, 근로계약의 한 당사자인 사용자로서는 특별한 사정이 없는 한 임금 외에는 근로자에게 어떠한 금품을 지급할 이유나 동기가 없다. 그러므로 사용자가 근로계약의 상대방인 근로자에게 어떤 금품을 지급하였다면 근로제공 외에 금품 제공의 원인이 될 수 있는 다른 이유나 동기가 있다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 임금 명목으로 그 금품을 지급한 것으로 봄이 합리적이다.²¹⁾ 그리고 그러한 근로제공 외에 다른 이유나 동기라고 할 만한 명확한 사정에 해당하는 것으로 들 수 있는 것이 바로 대법원이 근로의 대가성을 부정해 온 의례적·호의적인 지급과 실비변상이다.

따라서 근로계약관계가 인정되는 한, 사용자가 근로자에게 지급하는 금품은 원칙적으로 근로의 대가인 임금이므로, 그 금품이 임금이 아니라는 점에 관하여는

실질적으로는 근로자가 사용자가 의도하는 근로를 제공한 것에 대하여 그 대가로서 지급되는 것이 지 단순히 근로자로서의 지위를 보유하고 있다는 점에 근거하여 지급한다고 할 수 없으며, 이러한 수당 등을 지급하게 된 것이 현실의 근로제공과는 무관하게 단순히 근로자의 생활이나 지위를 보장하기 위한 것이라고 할 수도 없으므로, 이러한 수당 등을 현실적인 근로제공의 대가가 아닌 것으로 보는 것은 임금의 지급 현실을 외면한 단순한 의제에 불과하다(대법원 1995. 12. 21. 선고 94다 26721 전원합의체 판결).

21) 임금이 근로자에게 유일한 생활양식이므로 노동보호법규로서는 이를 되도록 넓고 명확하게 파악하는 것이 합리적이라는 견해(이정, “상여금(경영성과급)의 법적 성격에 관한 연구-일본과의 비교법적 고찰을 중심으로”, 외법논집 44권 2호, 법학연구소(2020), 145)도 같은 취지로 이해할 수 있을 것이다.

사용자 등 이를 주장하는 자가 증명하여야 한다고 봄이 타당하다.²²⁾

다. 평균임금, 통상임금과의 구별

다음으로, 사용자가 근로자에게 지급하는 특정 금품이 임금에 해당하는지의 문제와 평균임금, 통상임금에 해당하는지를 준별하여야 한다. 평균임금과 통상임금은 임금에 해당함을 전제로 그중 특정한 영역의 임금을 포섭하는 개념이다. 따라서 평균임금이나 통상임금의 요건(개념표지)에 해당하는지 여부로 임금성을 판단해서는 안 된다. 특히 평균임금이나 통상임금의 요건에 해당하지 않는다는 사정을 들어 평균임금이나 통상임금의 전제가 되는 임금성 자체를 부정해서는 안 된다.

1) 평균임금과의 구별²³⁾

평균임금이란, 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다.²⁴⁾ 평균임금의 정의 규정(근로기준법 제2조 제1항 제6호)만 보면, 산정 사유 발생일 이전 3개월 동안 지급된 임금이 평균임금이므로, 평균임금의 개념지표도 임금과 마찬가지로 일체의 근로의 대가라고 볼 여지가 있다. 그러나 근로기준법 시행령 제2조 제항은 ‘임시로 지급된 임금 및 수당’ 등을 평균임금에서 제외한다. 즉 산정 사유 발생일 이전 3개월 동안 지급된 임금에는 해당하지만 평균임금에는 해당하지 않는 영역이 존재하는 것이다.

물론 근로기준법 시행령 제2조는 법률의 위임이 없어 무효라는 논리도 가능

22) 노동법실무연구회(최은배 집필 부분)(주 1), 249.

23) 필자의 견해와 달리, 우리나라에서 말하는 임금은 평균임금을 말하는 것이고, ‘임시로 지급된 임금 및 수당과 통화 외의 것으로 지급된 임금’을 평균임금에서 제외한다고 하여 달리 볼 것은 아니라는 견해(노동법실무연구회(최은배 집필 부분)(주 1), 278)가 있으나, 통상적인 생활 유지를 위하여 사실적으로 산정된 통상적인 생활임금을 평균임금이라고 한다면 개념상 그러한 생활임금은 임금 중 일정한 범위에 한정되는 것이고 생활임금이 아닌 임금이 존재할 수밖에 없으므로 이러한 이해에는 찬성하기 어렵다. 만일 평균임금을 통상적인 생활 유지를 위하여 사실적으로 산정된 통상적인 생활임금에 국한하지 않는다면 평균임금과 임금을 같은 개념으로 볼 수 있으나 그렇게 되면 평균임금의 목적이나 취지를 벗어나서 모든 임금이 평균임금에 해당하게 되어 부당한 결론을 초래할 것이다.

24) 근로기준법 제2조 제1항 제6호, 평균임금 산정 사유로는 퇴직금(근로자퇴직급여 보장법 제8조), 휴업수당(근로기준법 제46조), 연차휴가수당(근로기준법 제60조 제5항), 휴업·장해·유족보상과 장례비, 일시보상(근로기준법 제79조, 제80조, 제82조, 제83조, 제84조), 산업재해보상보험법상 휴업·장해·유족급여, 상해보상연금, 장의비, 직업훈련수당 등 보험급여(산업재해보상보험법 제36조, 제52조, 제57조, 제62조, 제67조, 제71조, 제74조) 등이 있다.

하다. 그러나 평균임금이라는 제도의 목적이나 취지를 고려하면, 비록 근로기준법 시행령 제2조에 대한 법률의 위임이 없더라도, 근로기준법 제2조 제1항 제6호가 정하는 평균임금의 취지나 목적을 고려하여 법률해석으로, 근로기준법 시행령 제2조와 같은 결론을 도출할 수는 있다. 즉 평균임금이란 근로자의 통상적인 생활 임금을 사실대로 산정함으로써 법령이 정하는 산정 사유²⁵⁾ 발생을 전후하여 근로자가 통상적인 생활을 유지하도록 하는 데 목적이 있으므로,²⁶⁾ 그러한 목적에 부합하지 아니한 임금을 배제하는 것은 합리적인 해석의 범위 내에 있는 것이다.²⁷⁾ 다만 명문의 법령 규정 없이 법률해석으로 근로자의 권리를 제한하는 것이므로 그러한 해석은 엄격하고 신중하게 이루어질 필요가 있다.

한편 지급의 계속성·정기성이나 지급사유 또는 지급액의 사전확정성 여부는 통상적인 생활임금 해당 여부 즉 평균임금 해당 여부를 판단하는 지표일 뿐 근로의 대가성 자체를 판단하는 지표라고 볼 수는 없다.²⁸⁾ 지급의 계속성·정기성은 고정급적 상여금인지 일시급적 상여금인지를 구별하는 기준일 뿐이고, 만일 지급사유 또는 지급액의 사전확정성을 임금 요건으로 하면 지급사유 또는 지급액이 사전에 확정되어 있지 아니한 도급제 임금을 임금으로 포섭할 수 없는 모순이 발생한다.²⁹⁾

종래 대법원은 평균임금에서 제외되는 ‘임시로 지급된 임금 및 수당’(근로기준법 시행령 제2조 제2항)에 관하여, 일시적·돌발적 사유로 인하여 지급되는 것

25) 퇴직으로 인한 퇴직금(근로기준법 제34조, 근로자퇴직급여 보장법 제8조), 휴업으로 인한 휴업수당(근로기준법 제46조) 등은 평균임금을 기준으로 산정한다.

26) 김형배(주 16), 371; 노동법실무연구회(최은배 집필 부분)(주 1), 275; 이철수, “현행 임금제도의 비판적 검토”, 노동법연구 12호, 서울대학교 노동법연구회(2002), 133; 임종률, 노동법 17판, 박영사(2019), 411; 菅野和夫, 労働法 十一版補正版, 弘文堂(2017), 407; 荒木尚志, 労働法 三版, 有斐閣(2016), 136.

27) 대법원 또한 근로기준법 시행령 제2조가 유효함을 전제로 이에 따라 평균임금을 판단한다(대법원 1978. 12. 13. 선고 78다2007 판결, 대법원 1981. 10. 13. 선고 81다697 판결, 대법원 2003. 7. 25. 선고 2001다12669 판결, 대법원 2014. 9. 4. 선고 2013두1232 판결, 대법원 2019. 6. 13. 선고 2015다65561 판결 등).

28) 기영석, “성과급의 임금성에 관한 고찰”, 노동법률 통권 299호, 중앙경제사(2016), 80~81; 김기선(주 17), 81; 김홍영, “상여금의 임금성 여부”, 노동법연구 21호, 서울대학교 노동법연구회(2006), 74; 심재진(주 4), 111~112; 유성재(주 4), 29~30. 한편 지급액 또는 지급 여부가 사전에 확정되어야 한다는 것은 통상임금의 요건이 될 수 있을 뿐 실제 지급된 금액을 사후적으로 산정하는 평균임금의 요건일 수 없다는 견해로는, 유성재(주 4), 33.

29) 김홍영(주 28), 75; 문종철, “성과급 또는 상여금의 임금성에 관하여”, 우리법연구회 논문집 6집, 우리법연구회(2010), 455.

과 같은 그 지급사유 발생이 불확정적인 것을 말하는 것으로, 식대, 간식대 등 계속적, 정기적으로 봉급에 가산하여 지급하는 것은 제외된다고 판시하였는데,³⁰⁾ 이러한 판시는 임금성이 인정됨을 전제로, 지급의 계속성, 정기성 결여와 지급사유의 사전 불확정성을 평균임금에서 제외되는 임시로 지급된 임금으로 이해한 것으로 볼 수 있다.³¹⁾ 그리고 대법원의 이 부분 판시를 잘 보면, 지급사유의 사전확정성이 없으면 임시로 지급된 임금 및 수당에 해당하여 평균임금에서 제외되는 것이 원칙이지만, 지급의 계속성·정기성이 있으면 비록 지급사유의 사전확정성이 없더라도 임시로 지급된 임금 및 수당에 해당하지 아니하여 평균임금에 해당한다는 것이다. 이러한 대법원의 판단은 정당한 것으로 이해된다. 왜냐하면, 지급사유가 사전에 확정되어 있지 아니하면 특별한 사정이 없는 한 일회적으로만 지급될 뿐 이후에 반복적 지급을 기대할 수 없으므로 통상적인 생활 유지를 위해 필요한 평균임금에 해당하지 아니하는 것으로 볼 수 있지만, 비록 지급사유가 사전에 확정되어 있지 않더라도 계속, 정기적으로 지급된 것이라면 이후에 반복적 지급을 기대할 수 있으므로 통상적인 생활 유지를 위해 필요한 평균임금에 해당하는 것으로 봄이 타당하기 때문이다.³²⁾

그런 의미에서 보면, 일부 대법원판결들³³⁾이 지급의 계속성·정기성이나 지급사유 또는 지급액의 사전확정성 여부를 임금성 자체의 판단지표인 것처럼 판시하는 것은 적절하다고 볼 수 없다. 위 일부 대법원판결들은 실제로는 평균임금 해당성을 부정한 것들인데, 평균임금의 요건에 해당하지 않는다고 판단하는 것이 옳지 임금이 해당하지 않는다고 판단하는 것은 임금과 평균임금을 혼동하는 오류를 범하는 것이다. 최근 대법원판결들은, “평균임금 산정의 기초가 되는 임금은 사용

30) 평균임금산정의 기초가 되는 임금총액에 산입하지 않는, 임시로 지불된 임금과 수당이란 일시적, 우발적 사유로 인하여 지급되는 따위의 그 지급사유 발생이 불확정적인 것을 말하는 것이므로, 계속적, 정기적으로 봉급에 가산하여 지급하여 온 식대, 간식대 등은 이에 해당하지 아니한다(대법원 1978. 12. 13. 선고 78다2007 판결, 대법원 1981. 10. 13. 선고 81다697 판결, 대법원 1992. 4. 10. 선고 91다37522 판결, 대법원 1994. 9. 13. 선고 94다21580 판결 등).

31) 하갑래, 근로기준법, 중앙경제사(2019), 235에 의하면, 해외근로자 추가임금, 풍수해에 대한 재해수당, 돌발적 물가상승에 대비한 인플레이션수당 등이 임시로 지급된 임금 및 수당에 해당한다고 한다.

32) 대법원 1978. 12. 13. 선고 78다2007 판결은, 지급사유의 발생이 ‘사전’에 확정되었다는 아무런 자료가 없지만, 계속적·정기적으로 지급된 사정만으로 지급사유의 발생이 불확정적이지 않다고 하여 평균임금성을 인정한 사안이다.

33) 대법원 1998. 1. 20. 선고 97다18936 판결, 대법원 2002. 6. 11. 선고 2001다16722 판결, 대법원 2006. 5. 26. 선고 2003다54322, 54339 판결, 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012다48077 판결 등.

자가 근로의 대가로 근로자에게 지급하는 금품으로서, 근로자에게 계속적·정기적으로 지급되고 단체협약, 취업규칙, 급여규정, 근로계약, 노동관행 등에 의하여 사용자에게 그 지급의무가 지워져 있는 것을 말한다.”라면서,³⁴⁾ 지급의 계속성·정기성을 임금 자체가 아니라 평균임금의 판단지표로 판시하고 있는데, 타당하다고 볼 수 있다.

따라서 지급의 계속성·정기성이나 지급사유 또는 지급액의 사전확정성이 없다는 사정을 들어 임금성 인정을 전제로 평균임금성을 부정할 수는 있으나 임금성 자체를 부정할 수는 없다. 그러나 반대로 지급의 계속성·정기성이나 지급액의 사전확정성이 인정될 경우에는 임금의 하부개념인 평균임금의 판단지표를 충족하고 있으므로 임금에 해당한다고 판단할 수 있다.

한 가지 유의할 점은 임금성 요건인 근로계약 등에 의한 지급의무와 지급사유의 사전확정성은 서로 다른 개념이라는 것이다. 근로계약 등에 의한 지급의무는 근로계약 등으로 임금지급의무가 근거 지워져 있는지의 문제이고, 지급사유의 사전확정성은 지급사유의 반복적 발생이 미리 예정되어 있는지의 문제이다. 예컨대 실무상 임금협정을 체결하면서 소급하여 정기상여금 등을 인상하는 경우가 허다한데, 이 경우에 소급하여 지급되는 정기상여금은 임금협정 즉 단체협약에 의하여 지급의무가 근거 지워져 있어 근로의 대가에 해당하므로 임금에 해당한다. 그러나 당해 연도에 정기상여금의 소급 지급을 근거 지울 뿐 그와 같은 지급사유의 반복적 발생이 미리 예정되어 있었던 것은 아니다. 만일 어떤 회사가 근로자의 재직기간(10년이라고 하자) 중 단 한 차례 임금협정으로 정기상여금을 소급하여 지급하였다면 소급 지급된 정기상여금은 임금에는 해당하겠지만, 지급의 계속성, 정기성과 지급사유의 사전확정성이 없어 임시로 지급된 임금에 해당하여 평균임금에서는 제외될 수 있을 것이다.

2) 임금성이 문제 되는 사안과 평균임금이 문제 되는 사안

실무를 보면 대체로 평균임금이 문제 되는 사안에서 임금성을 혼용해서 다룬다. 앞서 본 바와 같이 임금과 평균임금을 구별해야 하므로, 평균임금성이 문제 되

34) 대법원 2018. 10. 12. 선고 2015두36157 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 2018다231536 판결, 대법원 2018. 12. 28. 선고 2016다239680 판결, 대법원 2018. 12. 28. 선고 2018다219123 판결 등.

지 않고 오로지 임금성이 문제 되는 사안과 평균임금성이 문제 되는 사안을 나눌 필요가 있다.

평균임금성이 문제 되지 않고 오로지 임금성이 문제 되는 사안은, ① 부당해고로 인한 임금청구 또는 임금 상당 손해배상청구 사안,³⁵⁾ ② 기간제, 무기계약직, 정규직 등을 구분하여 또는 정규직 내에 직군이나 직종을 구분해서 합리적 이유 없이 차별하는 경우 임금차액을 청구하거나 차액 상당 손해배상을 청구하는 사안, ③ 노노동무임금 원칙에 의하여 지급의무가 없는 쟁의행위기간 중의 임금을 산정할 필요가 있는 사안 등이다.

① 사안에 대한 예를 들면, 노사가 문제 된 근로자 재직기간 중 단 1회만 임금협정으로 일정한 기준에 따라 경영평가성과급을 지급하였는 데 당시 문제 된 근로자가 부당해고 중이어서 경영평가성과급을 받지 못했던 경우에, 다른 근로자들 모두가 지급받은 경영평가성과급을 부당해고된 근로자에게도 지급하여야 하는지가 문제 될 수 있다. 경영평가성과급이 임금이라면 평균임금에 해당하지 않더라도(지급사유의 사전확정성이 없고 지급의 계속성, 정기성이 없으면 평균임금성이 부정될 여지가 있다) 임금청구 내지 임금 상당 손해배상청구의 대상이므로 사용자는 부당해고당한 근로자에게도 지급할 의무가 있지만, 임금이 아니라면 임금청구 내지 임금 상당 손해배상청구의 대상이 아니므로 사용자는 부당해고된 근로자에게 위 금원을 지급할 의무가 없을 것이다.

② 사안에 대한 예를 들면, 노사가 문제 된 기간제근로자의 재직기간 중 단 1회만 임금협정으로 정규직(무기계약직) 근로자에게만 일정한 기준에 따라 경영평가성과급을 지급하였는 데 기간제근로자와 정규직(무기계약직) 근로자를 차별하는 데 합리적인 이유가 없었던 경우에, 문제 된 기간제근로자는 임금차액청구 또는 차액 상당 손해배상청구로 위 경영평가성과급 지급을 청구할 수 있는지가 문제 될 수 있다. 경영평가성과급이 임금이라면 평균임금에 해당하지 않더라도(위와 마찬가지로 평균임금성이 부정될 여지가 있다) 임금차액청구 내지 차액 상당 손해배상청구의 대상이므로 사용자는 부당해고당한 근로자에게도 지급할 의무가 있지만, 임금이 아니라면 임금차액청구 내지 차액 상당 손해배상청구의 대상이 아니므로 사용자는 부당한 차별에도 불구하고 근로자에게 위 금원을 지급할 의무가 없을 것이다.

35) 대법원 2011. 10. 27. 선고 2011다42324 판결 사안이 이에 해당한다.

3) 통상임금과의 구별

근로기준법에서 연장근로에 대한 가산임금 등의 산정 기준³⁶⁾ 및 평균임금의 최저한³⁷⁾ 등으로 통상임금을 정하고 있지만, 평균임금과 달리 통상임금에 대한 정의규정을 두고 있지 않다. 물론 근로기준법 시행령 제6조 제1항이 ‘근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정근로 또는 총근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액 또는 도급 금액’으로 통상임금을 정의하고 있기는 하다. 그러나 앞서 본 근로기준법 시행령 제2조와 마찬가지로 법률의 위임이 없다는 점에서 위 규정은 무효라는 논리가 가능하다.

대법원은 통상임금을 근로기준법 시행령 제2조와 곧바로 연결시키지 않고, ‘소정근로의 대가로 근로자에게 지급되는 금품으로서 정기적·일률적·고정적으로 지급되는 임금’으로 정의한다.³⁸⁾ 위 전원합의체 판결에 따르면, 통상임금의 요건(개념표지)은 소정근로의 대가, 정기성, 일률성, 고정성 등이라고 할 수 있다. 여기서 소정근로의 대가라 함은 근로자가 소정근로시간에 통상적으로 제공하기로 정한 근로에 관하여 사용자와 근로자가 지급하기로 약정한 금품을 말하고,³⁹⁾ 소정근로란 1일 8시간, 1주 40시간 등 법정근로시간 범위에서 근로관계 당사자 사이에 정한 근로시간 즉 소정근로시간에 통상 제공하기로 한 근로를 말한다.⁴⁰⁾

통상임금은 사후적 개념인 평균임금과 달리 임의의 근로를 제공하기 이전에 연장근로 등에 대한 가산임금을 산정할 수 있도록 함으로써 연장근로 등에 대한 의사결정을 가능하게 하는 도구로서 사전적 개념이다.

따라서 소정근로시간 중 통상 근로인 소정근로의 대가가 아니라거나, 정기성, 일률성, 고정성 등이 없다면 통상임금성이 부정될 수 있으나, 그러한 사정만으로 문제 되는 항목의 임금성이 부정될 수는 없다. 예컨대, 어떤 임금 항목이 근로제공 이전에 미리 정해져 있지 않거나(예컨대, 근로제공 후 소급적으로 지급되는 임금) 시간당 금액으로 환산되지 않는다는 사정이 있다고 하더라도 통상임금성이 부정될 수 있을 뿐 그 자체로 임금성을 부정할 수는 없다. 그러나 이 경우 역시

36) 근로기준법 제56조.

37) 근로기준법 제2조 제2항.

38) 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결.

39) 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결.

40) 노동법실무연구회(최은배 집필 부분)(주 1), 314; 임종률(주 26), 414.

반대로 소정근로 대가성, 정기성, 일률성, 고정성이 인정될 경우에는 임금의 하부 개념인 통상임금의 판단지표를 충족하고 있으므로 임금이 해당한다고 판단할 수 있다.

Ⅲ. 개인성과상여금의 임금성

1. 상여금의 유형

실무상 상여금은 성과상여금, 명절상여금, 우리나라에 독특한 형태라 할 수 있는 정기상여금 등으로 나뉜다.⁴¹⁾ 이와 관련된 대법원 등 법원의 실무를 간략히 요약하면 다음과 같다.

정기상여금은 근로의 대가 즉 (평균)임금에 해당할 뿐만 아니라 통상임금에도 해당한다고 봄이 일반적이다(통상임금에 해당하는 경우에 실무상 신의칙에 기한 지급 제한이 많이 문제 된다).⁴²⁾ 정기상여금은 성과와 결부된 것도 아니고, 명절 등 일정 시점에 특정 용도를 위해 지급되는 것도 아니며, 정기적으로 특정 기간 동안 소정근로의 대가로 주어지도록 사전에 정해져 있다는 점에서 임금 및 통상임금에 포함된다고 봄이 타당하다. 다만 재직조건이 붙은 정기상여금의 경우 기존의 대법원 전원합의체 판결⁴³⁾에서는 임금성이 인정됨을 전제로 소정근로의 대가가 아니라거나 고정성이 없다는 이유로 통상임금성을 부정해 왔는데, 학계에서는 통상임금의 요건으로 고정성을 부정하거나, 재직조건은 개인의 특수한 사정에 불과하다는 등을 이유로 재직조건의 유효성을 인정하더라도 고정성을 인정하거나, 임금의 사전포기에 해당하거나 강제근로금지에 반한다는 등을 이유로 재직조건 자체를 무효로 봄으로써 재직조건이 붙은 정기상여금의 통상임금성을 인정하는 견

41) ① 성과상여금은 회사의 경영성과 또는 근로자의 업무성과 등을 반영하여 가변적으로 주어지는 상여금으로서, 상여금의 원래 성격을 가장 잘 반영하고 있다고 볼 수 있다. ② 명절상여금은 성과와 결부된 것은 아니고, 특정 용도(설 또는 추석이라는 특정 시점의 생활 수요를 충족)를 위하여 일정 시점에 일정 금액이 정기적으로 지급될 것이 사전에 정해져 있다. ③ 정기상여금은 성과와 결부된 것도 아니고, 명절 등 일정 시점에 특정 용도를 위해 지급되는 것도 아니며, 정기적으로 특정 기간 동안의 소정근로의 대가로 주어지도록 사전에 정해져 있다.

42) 대법원 2002. 10. 25. 선고 2000두9717 판결, 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결, 대법원 2016. 1. 14. 선고 2012다96885 판결, 대법원 2019. 4. 23. 선고 2014다27807 판결, 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017다293629 판결, 대법원 2020. 5. 14. 선고 2019다18174 판결 등.

43) 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결.

해가 통설이다.⁴⁴⁾ 한편 최근 하급심에서 재직조건 자체를 무효로 보아 통상임금성을 인정하는 판결들이 선고되어⁴⁵⁾ 다시 대법원에서 전원합의체에 회부하여 논의 중이고, 재직조건을 유효하다고 보면서도 개인의 특수한 사정에 불과하다고 보아 고정성 나아가 통상임금성을 인정한 판결(서울고법 2020. 12. 2. 선고 2016나 2032917 판결)도 선고되어 상고심 계속 중이다(대법원 2020다300626호).⁴⁶⁾

명절상여금은 성과와 결부된 것은 아니고, 설 또는 추석이라는 특정 시점의 생활 수요를 충족한다는 특정 용도를 위하여 일정 시점에 일정 금액이 정기적으로 지급될 것이 사전에 정해져 있다. 명절상여금 역시 임금성이 인정됨을 전제로 소정근로의 대가가 아니라는 이유로 통상임금성을 부정함이 일반적이다. 다만 명목만 명절상여금이지 그 실질이 정기상여금과 같은 경우도 있을 수 있다.

성과상여금은, 근로자의 개인적 업무성과 또는 회사의 집단적 경영성과 등을 반영하여 가변적으로 주어지는 상여금으로서, 상여금의 원래 성격을 가장 잘 반영하고 있다고 볼 수 있다. 개인성과상여금과 집단성과상여금으로 나눌 수 있고, 다시 집단성과상여금을 사기업 집단성과상여금과 공기업 집단성과상여금으로 나누어 검토할 필요가 있다. 후술한다.

2. 개인성과상여금의 임금성에 관한 선행판례

개인성과상여금의 임금성에 관한 선행판례로는 대법원 2002. 5. 31. 선고 2000다18127 판결, 대법원 2004. 5. 14. 선고 2001다76328 판결, 대법원 2011. 3. 10. 선고 2010다77514 판결, 대법원 2011. 7. 14. 선고 2011다23149 판결 등이 있다. 이 중 대법원 2000다18127 판결, 대법원 2010다77514 판결, 대법원 2011다23149 판결 등은 임금성(평균임금성)을 인정한 것들이고, 대법원 2001다76328 판결은 임금성(평균임금성)을 부정한 것이다. 그 구체적인 내용은 다음과 같다.

가. 대법원 2000다18127 판결: 임금성(평균임금성) 인정(↔ 원심)⁴⁷⁾

44) 노동법실무연구회(최은배 집필 부분)(주 1), 323~330.

45) 서울고법 2018. 12. 18. 선고 2017나2025282 판결.

46) 필자로서는 종전 대법원 전원합의체 판결의 타당성에 의문이 있다고 생각하는데, 이 논문과 직접적인 관계가 없으므로 구체적인 기재를 생략한다.

47) 이 판결에 대한 대표적인 평석으로는, 강기탁(주 15) 참조(대법원판결에 찬성하는 취지).

피고는 구두판매회사이고, 원고는 피고 소속 근로자로 근무하다가 퇴직하였다. 원고들의 구두판매 실적에 따른 포상금이 퇴직금 산정을 위한 평균임금에 포함되는지가 쟁점이다. 사실관계는 다음과 같다.

① 원고는 근무시간 이외뿐 아니라 근무시간 중에도 상품권을 판매하기 위하여 노력하고 피고로부터 그 상품권판매액에 따라 일정한 비율의 포상금을 지급받았다.

② 포상금의 지급시기가 일정하지 아니하여 1995년에는 12월경, 1996년에는 5월경과 12월경, 1997년에는 5월경, 1998년에는 1월경에 각 지급되었고, 포상금의 액수도 피고가 필요에 따라 일방적으로 결정하는 판매실적금액에 대한 비율에 의하여 결정되었다.

③ 피고의 단체협약이나 취업규칙에는 위 포상금에 대하여는 규정된 내용이 없을 뿐 아니라 그에 관한 노사 간의 합의도 존재하지 아니하였다.

원심(서울고등법원 2000. 3. 7. 선고 99나48032 판결)은, 포상금이 근로의 대가인 임금에 해당하려면 피고가 직원들에게 이를 정기적, 계속적으로 지급하여야 할 뿐만 아니라 그 지급액이 일정하거나 적어도 일정한 기준에 의하여 미리 예정되어 있어야 할 것인데, 위 포상금은 피고가 그 지급시기와 지급금액을 정하는 비율을 필요할 때마다 일방적으로 정하여 지급한 것이므로, 임금의 성질을 갖는 것이 아니라 사용자인 피고의 호의에 의하여 은혜적으로 지급되는 급부라고 할 것이라는 이유로 평균임금에 포함되지 않는다고 판단하였다.

그러나 대법원은 다음과 같이 판시하면서 위 포상금이 평균임금에 포함된다고 판단하여 원심을 파기환송하였다.

이 사건 포상금은 피고가 매년 같은 시기에 같은 비율에 따라 지급하는 것이 아니라 피고가 일방적으로 정한 지급시기와 지급액수, 지급기준에 따라 지급하는 것이기는 하지만, 상품권판매는 구두류 제품판매를 주업으로 하는 피고가 역점을 두는 사업이므로 직원들이 상품권판매를 위하여 하는 영업활동은 결국 피고에 대하여 제공하는 근로의 일부라고 볼 수 있어 포상금은 근로의 대가로 지급되는 것이라고 보아야 하고, 기록에 나타난 자료에 의하면 포상금 지급은 해마다 그 지급시기는 다르나 매년 한두 차례 시행되는 것이 관례화되어 있음을 알 수 있으므로 이를 우발적, 일시적 급여라고 할 수 없으며, 피고가 해마다 미리 지급기준과 지급비율을

정하고 그에 따라 계산된 포상금을 지급하는 것인 이상 직원들이 그 요건에 맞는 실적을 달성하였다면 피고로서도 그 실적에 따른 포상금의 지급을 거절할 수 없을 것이므로 이를 은혜적인 급부라고 할 수도 없고, (중략), 개인포상금은 평균임금에 포함된다.

나. 대법원 2001다76328 판결: 임금성 부정⁴⁸⁾

피고는 유가증권 거래 및 중개 회사이고, 원고들은 피고 소속 근로자들로 근무하다가 퇴직하였다. 원고들은 재직조건이 근로자의 손해배상책임을 담보하기 위한 것이라면서 퇴직일을 불문하고 성과금의 지급을 구한 반면, 피고들은 성과상여금이 임금이 아닐 뿐만 아니라 단체협약이 정한 재직조건에 따라 일정 성과상여금을 지급하지 않는 것은 정당하다고 다툰 사안이다. 사실관계는 다음과 같다.

① 피고는 원래 기본급, 정기상여금, 특별상여금으로 구성되는 급여체계를 가지고 매년 고정된 상여금 지급률에 의한 상여금과 기본급을 사원들에게 지급하여 왔다. 그런데 피고회사와 피고회사의 노동조합은 1998. 6. 30. 영업직원에 대하여 정기상여금제도 대신 전면적인 성과급제도를 도입하였다.

② 피고가 위와 같은 성과급제도를 도입한 것은 영업 우수 직원에 대한 고액의 보수 지급으로 우수인력을 유지하고, 우수인력의 유인을 기대하고, 부진직원에 대한 보수 차등으로 생산성 향상을 촉진하기 위한 것이었다.

③ 그 후 피고회사와 피고회사의 노동조합은 1999. 7. 19. 성과급 지급방법을 변경하기로 하고, 분기별 성과지급기준액의 60%를 당해 분기에, 20%를 차분기에, 20%를 차차분기에 각 지급하는 것으로 합의하였다.

④ 원고들이 피고회사에서 퇴직함에 따라, 피고는 위 성과급 지급일 현재 재직 중인 자에 대하여만 성과급을 지급한다는 내용의 단체협약의 조항과 분기 중 퇴직 시에는 해당 성과급분을 지급하지 않는다는 내용의 근로계약에 따라 성과금을 산정하여 퇴직 당시 성과급을 제외하고 일부 성과급만을 원고들에게 지급하였다.

원심(서울고등법원 2001. 10. 19. 선고 2001나10092 판결)은 성과금을 상여금의 일종이라고 보면서, 성과금이 후불적 임금의 성격을 가진다 하더라도 지급일에

48) 이 판결에 대한 대표적인 평석으로는, 김홍영(주 18); 조영선, “성과급이 근로기준법상 임금에 해당 하는지”, 노동관계 비평(2005), 88 참조(대법원판결에 반대하는 취지).

재직하고 있는 자에 한하여 지급하는 규정을 유효하다고 하여 원고들의 청구를 배척하였다. 그러나 성과금이 평균임금에 해당하는지에 관하여는 명시적으로 판단하지 않았다.

대법원은 다음과 같이 판시하면서 위 성과금이 임금이 아님을 전제로, 원심과 마찬가지로 지급일 재직요건이 유효하다고 하여 원고들의 상고이유 주장을 받아들이지 않았다.

피고 회사가 영업직원에게 지급하는 이 사건 성과금은 근로자 개인의 실적에 따라 그 지급 여부와 지급액수가 결정되는 것인바, 근로자 개인의 실적에 따라 결정되는 성과금은 지급조건과 지급시기가 단체협약 등에 정하여져 있다고 하더라도 지급조건의 충족 여부는 근로자 개인의 실적에 따라 달라지는 것으로서 근로자의 근로제공 자체의 대상이라고 볼 수 없으므로 임금에 해당된다 할 수 없다.

다. 대법원 2010다77514 판결: 임금성(평균임금성) 인정

피고는 의료법인의 소송수계인이고, 원고는 의료법인 소속 근로자(의사)로 근무하다가 퇴직하였다. 원고들이 받은 진료포상비가 퇴직금 산정을 위한 평균임금에 포함되는지가 쟁점이다. 사실관계는 다음과 같다.

① 원고는 의료법인으로부터 그 ‘진료포상비지급기준’에 따라 기본급과 제 수당 외에 2008. 11.부터 2009. 1.까지 매월 진료포상비를 지급받았다.

② 진료포상비는 기본포상비, 특진포상비, 진료수익의 다과에 비례하는 성과포상비, 협진료 및 전과포상비로 구분되어 지급되었다.

③ 원고는 매월 기본포상비와 그 이외에 실적에 따른 성과포상비 등을 지급받았다.

원심(부산고등법원 2010. 8. 26. 선고 (창원)2010나1664 판결)은, 진료 등 의사 고유 업무 수행에 따라 받은 것이므로 근로의 대가이고, 의료법인 스스로 정한 진료포상비지급기준에 의하여 의료법인에 지급의무가 지워져 있어 은혜적인 급부라고 보기 어려우며, 계속적, 정기적으로 지급되었으므로 평균임금 산정의 기초가 된다면서, 진료포상금이 평균임금에 해당한다고 판단하였고, 대법원 또한 원심의 판단을 그대로 수긍하였다.

라. 대법원 2011다23149 판결: 임금성(평균임금성) 인정⁴⁹⁾

피고는 차량판매회사이고, 원고는 피고 소속 근로자로 근무하다가 퇴직하였다. 원고의 차량판매 실적에 따른 인센티브가 퇴직금 산정을 위한 평균임금에 포함되는지가 쟁점이다. 사실관계는 다음과 같다.

① 피고의 급여규정은 차량판매 대수에 따라 지급률을 달리하여 영업사원 인센티브를 정하면서 차량 총판매금액에 인센티브 지급률을 곱하여 판매수당을 지급하도록 정하고 있다.

② 원고는 피고로부터 차량판매 실적에 따른 인센티브로 2007. 1.부터 3월까지 일정한 금액을 지급받았다.

원심(수원지방법원 2011. 1. 28. 선고 2009나33003 판결)은, 차량판매는 피고 회사의 주업으로서 영업사원들이 차량판매를 위하여 하는 영업활동은 피고 회사에 대하여 제공하는 근로의 일부라 볼 수 있어 인센티브(성과급)는 근로의 대가로 지급되는 것이라고 보아야 하며, 매월 정기적, 계속적으로 이루어지는 인센티브의 지급이 개인근로자의 특수하고 우연한 사정에 의하여 좌우되는 우발적, 일시적 급여라고 할 수 없고, 지급기준 등의 요건에 맞는 실적을 달성하였다면 피고 회사로서는 그 실적에 따른 인센티브의 지급을 거절할 수 없을 것이므로 이를 은혜적인 급부라고 할 수 없다면서, 차량판매 인센티브가 평균임금에 해당한다고 판단하였고, 대법원 또한 원심의 판단을 그대로 수긍하였다.

3. 선행판례의 타당성 검토

지급사유 즉 지급조건과 지급시기 등이 미리 정해져 있다고 하더라도 실적 달성이라는 지급조건의 충족 여부가 미리 정해져 있지 않다는 이유로 개인성과상여금의 임금성을 부정한 대법원 2001다76328 판결은, 개인성과상여금의 임금성을 인정한 다른 선행판례들과 양립할 수 없음을 지적하지 않을 수 없다. 개인성과상여금의 임금성을 인정한 다른 선행판례 사안에서도 실적 달성이라는 지급조건의 충족 여부는 미리 정해져 있지 않기 때문이다.

대법원 2001다76328 판결은 타당하다고 할 수 없다. 앞서 살펴본 바와 같이 사용자가 지급하는 어떤 항목이 근로의 대가인지, 근로계약 등에 의하여 지급의무가

49) 이 판결에 대한 대표적인 평석으로는, 김태욱(주 17) 참조(대법원판결에 찬성하는 취지).

인정되는지 여부로 임금성을 판단하여야 하고, 지급사유 또는 지급액의 사전확정성은 임금성에 대한 판단요건이 될 수 없다. 근로자 개인이 제공한 근로의 성과는 그 자체로 근로제공과 밀접한 관련이 있다 할 것이므로 이에 대한 대가는 근로의 대가로 평가되어야 한다(대법원 2000다18127 판결은 이러한 법리를 분명히 하고 있다).⁵⁰⁾ 그리고 지급사유 즉 지급기준이나 지급조건이 미리 정해져 있거나 지급의 계속성, 정기성이 인정된다면 사용자가 임시로 또는 우발적으로 지급하는 것이라고 볼 수 없으므로 평균임금성도 인정된다고 볼 수 있다.

개인성과상여금의 임금성을 인정한 선행판결들은 모두 타당하다고 할 수 있으나, 대법원 2000다18127 판결은 두 가지 측면에서 추가적인 검토를 요한다.

첫째, 대법원 2000다18127 판결에서는 사용자의 지급의무를 명시적으로 근거지우는 근로계약, 단체협약, 취업규칙 등이 존재하지 않은 사안이어서 과연 근로계약 등에 의한 지급의무를 인정할 수 있는지가 문제 될 수 있다. 그런데 위 판결은 1995년부터 1998년까지 4년간 연 1회 또는 2회 계속적으로 포상금을 지급하였다는 사실관계로부터 노동관행에 의한 지급의무를 인정하였다.⁵¹⁾ 과연 주어진 사실관계로부터 노사 간에 향후에도 그 지급이 당연한 것으로 여겨질 정도로 관례가 형성되었다고 볼 수 있는지에 관하여는 평가를 달리 할 수 있을 것으로 보이는데, 4년 사이에 포상금을 지급하지 않은 해가 없었다는 점에서 보면 위 판결의 태도가 타당하다고 생각한다.

둘째, 4년간 매년 포상금을 지급하였다는 점에서 지급의 계속성, 정기성은 인정할 수 있지만, 근로제공 이후에 지급이 이루어졌을 뿐만 아니라 반복적 지급을 예정한 근로계약, 단체협약, 취업규칙 등이 없었다는 점에서 지급사유 즉 지급기준이나 지급조건이 미리 정해져 있지는 아니하므로 설령 임금성을 인정한다고 하더라도 평균임금성을 부정해야 하는 것 아닌지 문제 될 수 있다. 즉 선행판례들이 평균임금성을 판단할 때 주요 징표로 삼는 것이 지급사유의 사전확정성과 지급의 계속성, 정기성인데, 이 둘을 모두 충족해야 평균임금성이 인정되는지 하나만 충족하면 평균임금성이 인정되는지가 문제 되는 것이다. 그런데 노동관행에 따라 지급이 이루어진 사안에서는 지급의 계속성, 정기성이 인정됨은 명백한 데 지급사유의

50) 김홍영(주 18), 22.

51) 강기탁(주 15), 212~213.

사전확정성에 관하여는 양론의 여지가 있다. 4년간의 포상금 지급을 사후적으로 관찰하면 노동관행이 인정되지만 초기 포상금 지급 당시를 기준으로 하면 아직 노동관행이 인정되지 않는다고 볼 수 있어 일부 포상금에 대하여는 지급사유의 사전확정성이 없다고 평가할 수 있다. 그런데 지급사유의 사전확정성과 지급의 계속성, 정기성이 평균임금을 판단하는 주요 징표가 되는 것은 근로기준법 시행령 제2조 제2항이 정하는 임시로 지급된 임금 및 수당 즉 일시적·돌발적 사유로 인하여 지급되는 임금 및 수당인지가 문제 되기 때문이다. 지급사유의 사전확정성이 있거나 설령 지급사유의 사전확정성이 없다고 하더라도 지급의 계속성, 정기성이 있으면 이를 임시적 또는 우발적 지급이라고 볼 수는 없으므로 평균임금성이 배제되는 임시로 지급된 임금 및 수당이라고 할 수는 없다. 대법원 2000다18127 판결은 이러한 법리를 확인하였다는 점에서도 그 의의가 있다 할 것이다.

IV. 집단성과상여금의 임금성

1. 집단성과상여금에 관한 선행판례

가. 사기업 집단성과상여금

사기업 집단성과상여금의 임금성에 관한 선행판례로는, 대법원 1998. 1. 20. 선고 97다18936 판결, 대법원 2004. 5. 14. 선고 2001다76328 판결, 대법원 2011. 3. 10. 선고 2010다77514 판결, 대법원 2011. 7. 14. 선고 2011다23149 판결, 대법원 2011. 10. 27. 선고 2011다42324 판결 등이 있다. 대법원 2011다42324 판결만 임금성을 인정하였고,⁵²⁾ 나머지는 모두 임금성(평균임금성)을 부정하였다. 그 구체적인 내용은 다음과 같다.

1) 대법원 97다18936 판결: 임금성(평균임금성) 부정(↔ 원심)⁵³⁾

피고는 운송회사이고, 원고는 피고 소속 근로자로 근무하다가 퇴직하였다.

52) 임금성이 다투어진 것이지 평균임금성이 다투어진 것으로 볼 수는 없으므로 평균임금성을 인정하였다고 보기는 어렵다.

53) 이 판결에 대한 대표적인 평석으로는, 강성태, “작업출장비와 특별성과상여금이 평균임금에 속하는가”, 노동법률 통권 84호, 노동관계연구회(1999) 참조(대법원판결에 반대하는 취지).

1994. 7.에 지급된 경영평가에 따른 특별성과상여금이 퇴직금 산정을 위한 평균임금에 해당하는지가 쟁점이다. 사실관계는 다음과 같다.

① 피고 회사에서는 1994. 7. 5. 1994년도 임금 및 근로조건 개선에 관한 노사 간 협정이 체결되어 매년 3, 6, 9, 12월에 각 100%, 설날과 추석에 각 50% 지급되는 정기상여금 500%와 성과상여금 50%를 기본으로 그 외 1994년도 경영실적에 따라 연내에 50%의 특별성과상여금을 추가 지급하기로 약정하였고, 이에 따라 피고는 추가 지급하기로 한 50%의 특별성과상여금을 전 직원에게 1994. 7.에 지급하였다.

② 그 뒤 1995. 7. 25. 체결된 피고 회사의 1995년 임금 및 복지후생 개선에 관한 노사협정에서는 1994년도에 약정된 정기상여금 500%와 성과상여금 50% 및 특별성과상여금 50%를 합한 600%를 기본으로 하고 여기에 1995년도 경영실적에 따라 연내에 30%의 특별상여금(성과상여금이란 용어를 사용하지 않음)을 추가 지급하기로 하는 약정이 이루어지고, 이에 따라 피고는 1995년도에 전체 직원에게 30%의 특별상여금을 포함한 630%의 상여금을 지급하였다.

원심(서울지방법원 1997. 4. 11. 선고 96나31146 판결)은, 위 특별성과상여금이 일시적, 우발적이거나 은혜적, 호의적으로 지급된 것이고 볼 수 없고 근로의 대가로 지급되는 임금의 성질을 가진다면서 평균임금성을 인정하였다.

그러나 대법원은 다음과 같이 판시하면서 위 특별성과상여금이 임금에 해당하지 않는다는 이유로 원심을 파기환송하였다.

상여금이 계속적·정기적으로 지급되고 그 지급액이 확정되어 있다면 이는 근로의 대가로 지급되는 임금의 성질을 갖는다고 할 것이나, 그 지급사유의 발생이 불확정이고 일시적으로 지급되는 것은 임금이라고 볼 수 없다.

1994년도 임금협정에 규정된 특별성과상여금의 지급 조건은 '1994년도의 경영실적에 따라' 연내에 특별성과상여금 50%를 지급한다는 것이므로 그 지급 여부가 확정되어 있다고 볼 수 없다. 또한 원고는 1995. 4. 22. 퇴직하였으므로 위 특별성과상여금이 평균임금에 해당하는지의 여부도 원고가 퇴직할 당시를 기준으로 판단하여야 할 것인데, 원고가 퇴직할 무렵에는 위와 같은 특별성과상여금이 단 1회 지급되었을 뿐이고 앞으로 계속 지급될지의 여부가 불확실한 상태였으므로 그것이 계속적·정기적으로 지급되었다고 할 수도 없다.

2) 대법원 2001다16722 판결: 임금성(평균임금성) 부정

피고는 의류시험연구를 하는 재단법인이고, 원고들은 피고 소속 근로자로 근무하다가 1996년에 퇴직하였다. 피고가 원고에게 지급한 특별성과금이 퇴직금 산정을 위한 평균임금에 해당하는지가 쟁점이다. 사실관계를 보면, 피고는 1995년에 원고들에게 특별성과금을 단 1회 지급하였을 뿐이고, 특별성과금에 관한 별도의 자료는 없다.

원심(서울고등법원 2001. 2. 6. 선고 2000나32026 판결, 제1심⁵⁴⁾ 인용)은, 특별성과금이 그 후에도 매년 정기적으로 지급되는 임금의 성격을 갖는다고 인정하기에 부족하다는 이유로 특별성과금의 평균임금성을 부정하였다.

대법원은 다음과 같이 원심과 같은 취지로 판시하면서 역시 특별성과금의 평균임금성을 부정하였다.

원고들이 퇴직할 당시를 기준으로 할 때에는 1995년도 특별성과금이 단 1회 지급되었을 뿐이고 향후 특별성과금이 계속 지급될지 여부가 불확실한 상태였다 할 것이어서 그것이 계속적·정기적으로 지급된 것으로서 임금으로의 성격을 가진다고 보기 어려우므로 급여규정에 정해진 퇴직금 산정 시의 기준급여에 포함되는 상여금에 해당한다고 볼 수 없다.

3) 대법원 2003다54322, 54339 판결: 임금성(평균임금성) 부정(↔ 원심)⁵⁵⁾

피고는 조선업을 하는 회사이고, 원고들은 피고 소속 근로자로 근무하다가 퇴직하였다. 경영평가에 따른 경영성과금이 퇴직금 산정을 위한 평균임금에 해당하는지가 쟁점이다. 사실관계는 다음과 같다.

① 피고는 1992년도 임금협약에 노동조합원들에게 성과금으로 통상임금의 146%에 해당하는 금원을 연말에 지급한다고 정한 이래, 1993년에는 상여금의 150%를 그 해 연말에, 1994년에는 경영성과금으로 상여금의 100%를, 생산목표달성 성과금으로 상여금의 50%를 각 그 해 연말에, 1995년에는 당해 연도의 무쟁의를 조건으로 하여 성과금으로 상여금의 150%를 그 해 연말에, 1996년에는 경영성

54) 서울지법 서부지원 2000. 5. 12. 선고 99가합10134 판결.

55) 이 판결에 대한 대표적인 평석으로는, 김홍영(주 28)(개인성과금과 집단성과금 모두에 대하여 임금성을 인정하여야 한다고 하면서도 무분규가 지급조건인 경우에는 임금성을 부정하여야 한다면서 결론적으로는 대법원판결에 찬성하는 취지); 문종철(주 29)(대법원판결에 반대하는 취지) 참조.

과금으로 통상임금의 200%를 그 해 연말에 각 지급하기로 임금협약을 통해 약정하였으며, 1997년에는 1998. 1. 말에 경영성과금으로 상여금의 200%를 지급하되, 1997년 말까지 파업 등의 분규로 조업중단 사태가 발생할 경우 이를 보장하지 못하며 분규참가자는 지급대상에서 제외한다고 규정하였고, 1998년에는 경영성과금으로 상여금의 200%를 지급하되, 임금협약 타결 즉시 100%를, 1998. 12. 말에 나머지 100%를 각 지급하고, 그 지급일까지 어떠한 이유로도 파업이 발생할 경우에 성과금 전액은 자동 취소된다고 규정하였으며, 원고들이 퇴직한 이후인 1999년에는 합법적인 조합 활동과 산업평화유지를 전제로 경영성과금 200%(상여금 지급기준)를 연말에 지급할 것을 보장한다고 규정하고, 2000년에는 연말에 목표달성 성과금 200%(상여금 지급기준)를 지급할 것을 보장하되, 단 2000년 말까지 파업 등의 분규 발생 시 성과금의 지급을 보장하지 못하고 파업 등 쟁의행위 참가자는 지급대상에서 제외한다고 규정하였고, 2001년에는 그 해 연말 또는 다음 해 연시에 2001년 생산목표달성을 전제로 상여금의 200%에 해당하는 금원을 경영성과금으로 지급하기로 하고, 2002년에는 연말에 상여금의 200%에 해당하는 금원을 지급하기로 하되, 임금협약 타결 시까지 파업 등의 분규발생 시 성과금을 지급하지 않기로 규정하고 있으며, 아울러 위 2002년도 임금협약서에는 근무일수에 따라 일할 계산하여 성과금을 지급한다는 것을 규정하고 있고, 그 이전의 역대 임금협약서에는 위와 같은 성과금의 일할 계산 지급에 관한 규정이 없었다.

② 이에 피고는 1992년부터 현재까지 매년 전체 근로자들에게 위 각 임금협약에서 정한 바와 같은 기준으로 산정한 성과금을 지급하였는바, 노사 간 임금협상과정에서 8일간의 전면 파업 및 10일간의 부분파업이 있었던 1996년도에도 연말에 경영성과금이 전액 지급되었고, 이러한 성과금의 지급은 피고 회사의 사업장에서의 노동쟁의 발생 방지에 기여하였다.

원심(서울고등법원 2003. 9. 18. 선고 2002나18697, 18703 판결)은 다음과 같이 판시하면서 경영성과금이 퇴직금 산정을 위한 평균임금에 해당한다고 판단하였다.

1992년 처음으로 경영성과금 및 생산장려격려금이 지급될 무렵에는 아무런 조건이 부가되지 않았고, 1995년부터 무쟁의 내지 임금협상의 조기타결 등의 조건이 임금협약에 기재되기 시작한 점, 1996년에는 실제로 임금을 둘러싸고 단체협상 중 수

차례 부분파업 및 전면파업이 있었음에도 경영성과금 및 생산장려격려금이 정상적으로 지급된 점(다만 1996년도 임금협약에는 “무쟁의”라든가 “임금협상의 조기타결”과 같은 조건이 기재되어 있지는 않다), 경영성과금은 1996년 이후에는 그 명칭만 조금씩 달리할 뿐 그 지급액, 지급시기 등이 일정한 점에 비추어 보면, 경영성과금은 임금협약에 의하여 피고 회사가 전체 근로자들에게 일률적으로 지급하도록 의무지워진 것으로서 그 지급규정이나 명목 등 형식적인 사항만을 고려하여 그 지급사유의 발생이 불확정적이고 일시적으로 지급되는 것이라거나 의례적, 은혜적 급부라고 볼 수는 없고, 위 성과금을 전체적, 실질적으로 파악할 때 근로의 대가로서 지급되는 임금의 성질을 갖는다고 할 것이다.

그러나 대법원은 다음과 같이 관시하면서 특별성과금이 임금에 해당하지 않는다면 원심을 파기환송하였다.

피고의 성과금은 급여규정이나 단체협약에 규정된 바 없이, 매년 임금협약 시 노사 간 합의로 그 지급 여부나 구체적인 지급기준 등이 정해졌고, 위 1992년도부터 원고들이 모두 퇴직한 1998년도까지의 기간 동안에는 성과금의 지급기준이 거의 매년 틀려 그 지급액이 확정되어 있었다고 보기 어려운 점, 1994년도까지는 비록 아무런 지급조건이 부가되지는 않았으나, 그 지급기준이 일정하지 않았고, 1995년도부터 원고들이 모두 퇴직한 1998년도까지는 1996년도 한 해를 제외하고 모두 무쟁의 내지 무분규 등의 지급조건이 부가된 점, 피고 회사는 매년 노사합의에서 정한 바대로 빠짐없이 성과금을 지급하였는데, 이는 1996년도를 제외하고는 지급조건에서 정한 쟁의나 분규가 없었기 때문이었고, 1996년도에는 비록 분규가 있었지만 그 성과금 지급에 있어 ‘무분규’ 등과 같은 지급조건이 부가되지 않았기 때문인 것으로 보일 뿐, 이로써 분규 발생에도 불구하고 피고 회사가 일정률의 성과금을 계속 지급할 의사가 있다거나 그와 같은 관행이 성립되었다고 보기는 어려운 점 등을 종합하면, 원고들이 평균임금 산정의 기초가 되는 임금총액에 산입되어야 한다고 주장하는 1997년 및 1998년도 경영성과금은 계속적·정기적으로 지급되어 온 것으로서 근로계약이나 노동관행 등에 의하여 피고 회사에 그 지급의무가 지워져 있는 것으로 보기는 어려우므로, 평균임금 산정의 기초가 되는 임금에 해당하지 아니한다 할 것이다.

4) 대법원 2012다48077 판결: 임금성(평균임금성) 부정

피고는 생명보험회사이고 원고는 피고 소속 근로자(임원)로 근무하다가 퇴직하였다. 피고가 지급한 정기성과급(LTI, Long Term Incentive)이 퇴직금 산정을 위한 평균임금에 해당하는지가 쟁점이다. 사실관계는 다음과 같다.

① 원고는 2003. 1. 1. 입사 후 3년이 경과한 2006년부터 2009년까지 매년 3. 20.경 피고로부터 LTI 명목의 금원을 지급받았다.

② 원고에 대한 고용계약서에, LTI는 일반적인 취업조건과 완전히 다른 사안이고, 고용계약의 일부가 아니며, 회사가 원고에게 그에 참여하도록 제안할 계약상의 의무를 지지 않는다고 기재되어 있고, 원고가 피고로부터 받은 이메일에는 LTI는 고용계약조건을 구성하지 않고, 그 내용을 기밀로 유지하지 않으면 배당 자격을 상실한다고 기재되어 있다.

③ 피고는 임원으로 4년 이상 근무한 임원 모두에게 4년째부터 일정액의 LTI를 매년 연속으로 지급하는 것이 아니라 피고의 회계성과에 따라 그 대상자와 지급액을 달리 하였다.

원심(서울고등법원 2011나59294 판결)은, LTI가 계속적·정기적으로 지급되고 그 지급액이 확정되어 있다고 단정하기 어렵다면서 평균임금성을 부정하였다.

대법원은 다음과 같이 판시하면서 LTI의 평균임금성을 부정한 원심의 판단을 수긍하였다.

상여금이라 하더라도 계속적·정기적으로 지급되고 지급대상, 지급조건 등이 확정되어 있다면 이는 근로의 대가로 지급되는 임금의 성질을 가지나, 그 지급사유의 발생이 불확정적이고 지급조건이 경영성과나 노사관계의 안정 등과 같이 근로자 개인의 업무실적 및 근로의 제공과는 직접적인 관련이 없는 요소에 의하여 결정되도록 되어 있어 그 지급 여부 및 대상자 등이 유동적인 경우에는 이를 임금이라고 볼 수 없다. (중략) 원고에게 4년 연속 LTI가 지급되기는 하였지만, 이는 매년 피고가 그 재량으로 원고를 LTI 지급대상자로 선발하였기 때문이지 일정 자격 이상의 임직원들에게 LTI를 지급하기로 하는 관행이나 관례가 성립하였기 때문은 아니라고 보인다.

5) 대법원 2011다42324 판결⁵⁶⁾: 임금성 인정(↔원심)

피고는 선박 건조 등을 하는 회사이고, 원고는 피고 소속 근로자로 근무하다가 부당하게 징계해고되었다. 성과배분상여금이 부당해고로 인한 임금청구의 대상이 되는지, 즉 성과배분상여금이 임금인가가 쟁점이다.⁵⁷⁾ 사실관계는 다음과 같다.

① 피고의 급여규칙에는 피고의 경영성과와 연동하여 경영실적에 따라 성과배분상여금을 지급할 수 있다면서 지급사유와 지급기준을 정하고 있다.

② 성과평가기간은 매년 1. 1.부터 12. 31.까지이고, 성과평가시기는 그 다음 해 주주총회 이후이다.

③ 피고는 2001년 이후 원고 재직기간(2008. 12. 31.까지) 동안 정기적, 계속적으로 성과배분상여금을 지급해 왔다.

원심(서울고등법원 2011. 4. 29. 선고 2010나10766 판결)은, 성과배분상여금은 근로의 대상으로 지급되는 것으로 보기 어렵다는 이유로, 성과배분상여금의 임금성을 부정하였다.

그러나 대법원은, 지급사유의 발생이 불확정이고 일시적으로 지급되는 것이라면 임금으로 보기 어려우나, 계속적·정기적으로 지급되고 그 지급액이 확정되어 있다면 이는 근로의 대가로 지급되는 임금의 성질을 갖는다는 종전 법리(대법원 2006. 5. 26. 선고 2003다54322, 54339 판결 참조)를 토대로, 성과배분상여금의 임금성이 인정된다고 판단하여 원심을 파기환송하였다.

나. 공기업 집단성과상여금

공기업 집단성과상여금의 임금성에 관한 선행판례로는, 대법원 2018. 10. 12. 선고 2015두36157 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 2018다231536 판결, 대법원 2018. 12. 28. 선고 2018다219123 판결, 대법원 2018. 12. 28. 선고 2016다239680 판결 등이 있다. 모두 임금성(평균임금성)을 인정하였다. 그 구체적인 내용은 다음과 같다.

56) 환송 후 원심(서울고법 2012. 7. 20. 선고 2011나92567 판결)에서는 환송판결 취지에 따라 성과배분상여금 지급의무를 인정하였고, 피고가 환송 후 원심에 대하여 상고를 제기하였으나 심리불속행 기각(대법원 2012. 11. 29.자 2012다76867 판결)으로 확정되었다.

57) 퇴직금 등의 산출기준인 평균임금 해당 여부는 쟁점이 아니다.

1) 대법원 2015두36157 판결: 임금성(평균임금성) 인정

피고는 근로복지공단이고, 원고의 아들은 한국감정원 소속 근로자로 근무하다가 업무상 재해로 사망하였다. 한국감정원이 망인에게 지급하였던 성과상여금이 원고에게 지급할 유족급여 및 장의비 산정을 위한 평균임금에 해당하는지가 쟁점이다. 사실관계는 다음과 같다.

① 한국감정원의 보수규정 제32조 제2항은 “성과상여금 중 150%는 2월 첫 영업일에 지급하며, 잔여 성과상여금은 정부산하기관 관리기본법 제11조의 규정에 의한 경영평가 결과가 공표된 날로부터 30일 이내에 전년도 성과에 따라 차등 지급한다.”라고 정하고 있고, 보수규정 제33조 제3항은 “잔여 성과상여금의 지급대상 및 기준 등 구체적 사항은 경영계획 및 평가규정 제19조의 규정에 의한 내부경영평가편람에 따른다.”라고 정하고 있다. 한국감정원의 내부경영평가편람(2008년)은 잔여 성과상여금의 적용대상, 지급시기, 정부가 정한 성과급 지급률을 기초로 차등지급률을 산정하는 방법, 지급대상과 기준 등을 구체적으로 정하고 있다.

② 구 정부산하기관 관리기본법(2007. 1. 19. 법률 제8258호로 폐지) 제11조 제1항은 일정한 요건에 해당하는 정부산하기관에 대해 주무기관의 장이 경영실적을 평가하도록 정하고 있었다. 위 법률이 폐지되면서 제정·시행된 공공기관운영법 제48조 제1항은 기획예산처장관(2008. 2. 9. 법률 제8852호로 정부조직법이 개정된 이후에는 기획재정부장관으로 변경)이 공기업·준정부기관의 경영실적을 평가하도록 정하였다. 정부는 한국감정원이 정부산하기관에 해당하는 기간 동안에는 구 정부산하기관 관리기본법에 의한 경영실적평가 결과에 따라, 공공기관운영법 시행 이후에는 공공기관운영법에 의한 경영실적평가 결과에 따라 한국감정원에 적용되는 성과급 지급률을 정하였다.

③ 한국감정원은 위와 같이 매년 정부가 정한 성과급 지급률을 기초로 보수규정과 내부경영평가편람에서 정한 기준과 계산방식에 따라 잔여 성과상여금을 산정하여 소속 직원들에게 지급하였다.

④ 한국감정원은 2008년도에도 정부가 정한 성과급 지급률을 기초로 보수규정과 내부경영평가편람에 따라 망인에게 2008. 2. 1. 성과상여금을, 2008. 7. 16. 잔여 성과상여금을 지급하였고, 망인이 사망한 이후 퇴직금을 지급할 때에도 위와 같이 지급한 성과상여금을 모두 포함하여 평균임금을 산정하였다.

원심(서울고등법원 2014. 12. 19. 선고 2014누62908 판결, 제1심⁵⁸⁾ 인용)은, 다음과 같이 판시하면서 위 성과상여금이 평균임금에 해당한다고 판단하였다.

그 지급액이 미리 확정되어 있지는 않더라도 취업규칙 등에 일정한 근로기간에 근무한 근로자에게 상여금이 지급된다는 점, 그리고 지급액을 결정하기 위한 구체적인 기준, 지급의 시기 등이 규정되어 있어서, 사용자에게 위와 같은 기준이 확정되면 근로자에게 일정한 상여금을 지급하여야 할 의무가 인정되고, 실제로 상당한 기간 동안 위 규정에 따른 상여금이 지급되었다면 해당 상여금도 근로자들에게 계속적, 정기적으로 지급되는 근로의 대가로서 평균임금 산정의 대상이 되는 '임금'에 해당한다고 봄이 마땅하다.

대법원은 다음과 같은 판시를 추가하면서 경영평가성과급의 평균임금성을 인정한 원심의 판단을 그대로 수긍하였다.

평균임금 산정의 기초가 되는 임금은 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 지급하는 금품으로서, 근로자에게 계속적·정기적으로 지급되고 단체협약, 취업규칙, 급여규정, 근로계약, 노동관행 등에 의하여 사용자에게 그 지급의무가 지워져 있는 것을 말한다(대법원 2001. 10. 23. 선고 2001다53950 판결 등 참조).

경영평가성과급이 계속적·정기적으로 지급되고 지급대상, 지급조건 등이 확정되어 있어 사용자에게 지급의무가 있다면, 이는 근로의 대가로 지급되는 임금의 성질을 가지므로 평균임금 산정의 기초가 되는 임금이 포함된다고 보아야 한다. 경영실적평가 결과에 따라 그 지급 여부나 지급률이 달라질 수 있다고 하더라도 그러한 이유만으로 경영평가성과급이 근로의 대가로 지급된 것이 아니라고 볼 수 없다.

2) 대법원 2018다231536 판결: 임금성(평균임금성) 인정⁵⁹⁾

피고는 공항을 효율적으로 건설, 관리, 운영하기 위해 '한국공항공사법'에 따라 설립된 법인이고, 원고들은 피고 소속 근로자로 근무하다가 퇴직하였다. 피고가 지급한 경영평가성과급이 퇴직금 산정을 위한 평균임금에 해당하는지가 쟁점이다. 사실관계는 다음과 같다.

58) 서울행법 2014. 8. 13. 선고 2013구단4289 판결.

59) 이 판결에 대한 대표적인 평석으로는, 심재진(주 4); 유성재(주 4) 참조(대법원판결에 찬성하는 취지).

① 피고는 단체협약 등에 따라 소속 근로자들에게 기본 월봉, 경영평가성과급 등의 명목으로 임금을 지급해 왔다.

② 피고는 직원연봉규정 및 직원연봉규정 시행세칙에서 경영평가성과급 등 성과급 관련 규정을 두고 있다.

원심(서울고등법원 2018. 4. 17. 선고 2017나2053447 판결, 제1심⁶⁰⁾ 거의 인용)은 다음과 같이 판시하면서 경영평가성과급의 평균임금성을 인정하였다.

다음과 같은 사정들 등을 종합하여 보면, 경영평가성과급은 퇴직금 산정의 기초가 되는 평균임금에 해당한다고 보는 것이 타당하다.

① 피고는 평가대상 기간에 재직한 직원에 대하여 피고의 직원연봉규정에 따라 경영평가성과급을 지급하는 점,

② 피고의 직원연봉규정 제4조 제8호에서는 ‘평균임금’을 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안 지급된 ‘기본 월봉 및 연봉 외 급여를 삼등분한 금액과 사유 발생 직전 1년간 지급된 성과급 중 기본 월봉의 250% 등을 12등분 한 금액을 합산한 금액을 말한다.’라고 정하고 있어 경영평가성과급을 평균임금에서 제외하지 않고 있는 점,

③ 피고의 직원연봉규정과 직원연봉규정 시행세칙은 피고에게 경영평가성과급 지급의무가 있음을 전제로 지급기준, 지급방법 및 지급시기 등을 정하고 있고, 피고도 소속 직원들에게 경영평가등급에 따른 경영평가성과급을 예외 없이 지급하였는바, 피고는 경영평가성과급의 지급을 충분히 예상할 수 있었고, 피고의 직원들에게도 경영평가성과급이 지급될 것이라는 기대가 형성되었다고 볼 수 있는 점,

④ 경영평가성과급이 달리 은혜적 금품에 불과하거나 근로자의 특수하고 우연한 사정에 의해 좌우되는 우발적·일시적 급여라고 볼 만한 다른 근거가 없는 점,

⑤ 피고의 직원 보수는 기본연봉, 연봉 외 급여, 성과급 및 성과연봉으로 구성되는데, 경영평가성과급은 자체평가성과급과 함께 성과급에 해당하고 실제 근무일수에 따라 일할 계산하여 지급되는 것을 원칙으로 하고 있는 등 근로의 대가인 임금에 해당한다고 보아야 하는 점,

⑥ 경영평가성과급은 전년도 피고의 경영실적평가 결과에 따른 지급률에 대하여 내부 경영실적평가 결과를 반영하여 지급액이 결정되는 것으로서 매년 원고들에게

60) 서울남부지법 2017. 8. 18. 선고 2016가합109360 판결.

예외 없이 지급되어 왔으므로, 경영평가성과급의 최저지급률과 최저지급액이 정해져 있지 않고 그 지급액이 매년 새로이 결정된다고 하여, 경영평가성과급이 일시적으로 지급되는 것이라거나 그 지급사유의 발생이 불확정적이라고 볼 수는 없는 점,

⑦ 경영평가성과급이 취업규칙에 해당하는 피고의 직원연봉규정 등에 의하여 피고에게 지급의무가 지워져 있고 평균임금 산출 기초에 포함되어 있는 이상, 설령 피고가 기획재정부의 2012년도 공기업·준정부기관 예산편성지침에 따라 경영평가성과급을 퇴직금 산정 기준이 되는 평균임금에서 제외하여 왔고 이에 피고의 직원들이 이의를 제기하지 않았다고 하더라도, 그러한 사정만으로 경영평가성과급이 평균임금에 포함되지 않는다고 할 수는 없는 점

대법원은 다음과 같은 판시를 추가하면서 경영평가성과급의 평균임금성을 인정한 원심의 판단을 그대로 수긍하였다.

2012년부터는 공공기관 경영평가성과급의 최저지급률과 최저지급액이 정해져 있지 않아 소속 기관의 경영실적평가 결과에 따라서는 경영평가성과급을 지급받지 못할 수도 있다. 이처럼 경영평가성과급을 지급받지 못하는 경우가 있다고 하더라도 성과급이 전체 급여에서 차지하는 비중, 그 지급 실태와 평균임금 제도의 취지 등에 비추어 볼 때 근로의 대가로 지급된 임금으로 보아야 한다.⁶¹⁾

3) 대법원 2018다219123 판결: 임금성(평균임금성) 인정

피고는 한국산업인력공단이고 원고들은 피고 소속 근로자로 근무하다가 퇴직하였다. 피고가 지급한 경영평가성과급이 평균임금에 해당하는지가 쟁점이다. 피고의 관련 규정은 다음과 같다.

61) 대법원의 이 부분 판시에 관하여, 논리의 일관성 측면에서는 물론 법적 안정성 측면에서도 문제가 있다는 견해로는, 유성재(주 4), 33 참조.

피고 보수규정

제23조(성과급)

성과급은 성과에 따라 연봉월액을 기준으로 연 100% 이상 지급하되, 차등지급할 수 있다.

피고 연봉제 시행규칙

제17조(성과급의 구분 및 지급기준)

① 성과급은 특별성과급, 자체성과급, 경영평가성과급으로 구분하고, 일반직 3급 이하 직원(팀장 보직자 제외)의 특별성과급과 자체 성과급은 각 연봉월액의 100%에 해당하는 금액을 말하며, 성과연봉제 대상 직원의 자체성과급은 연봉월액의 60%에 해당하는 금액을 말한다. 경영평가성과급은 매년 정부경영평가 결과에 따른 지급률로 결정되는 금액을 말한다.

제18조(지급시기)

① 성과연봉은 당해 연도 지급 시 B등급을 기준으로 지급하되, 매년도 경영평가 결과 발표 이후 [별표 5]의 차등비율에 따라 정산하여 지급할 수 있다.

제19조(평가의 원칙)

연봉적용을 위한 능력평가는 경영평가 결과에 의한다.

제20조(평가등급의 분포비율)

① 연봉제운영 주관부서장은 경영평가 결과에 따라 개인별 또는 부서(팀)별로 구분하여 다음 각호의 분포비율에 의거 인원을 배분한다. 다만 동 분포비율은 연봉조정 위원회에서 재조정할 수 있다.

1. S등급 10% 2. A등급 15% 3. B등급 50% 4. C등급 15% 5. D등급 10%

[별표 4] 성과급 차등지급률

등 급	S	A	B	C	D
차등비율	135%	117.5%	100%	82.5%	65%

원심(부산고등법원 2018. 1. 24. 선고 2017나57113 판결, 제1심⁶²⁾ 인용)은 다음과 같이 판시하면서 경영평가성과급의 평균임금성을 인정하였다.

62) 울산지법 2017. 9. 27. 선고 2016가합22048 판결.

다음과 같은 사정들 등을 종합하여 보면, 성과연봉은 퇴직금 산정의 기초가 되는 평균임금에 해당한다고 보는 것이 타당하다.

① 성과연봉을 12로 나눈 연봉월액이 매월 피고의 임직원인 원고들에게 보수의 일부로서 지급된 점,

② 피고 연봉제 시행규칙의 [별표 8]에서 특정한 직급별 성과연봉 지급기준에 따라 피고 소속 근로자들의 직급 및 직책별로 일률적으로 정해진 금액의 성과연봉이 지급되는 점,

③ 피고 보수규정이나 피고 연봉제 시행규칙 어디에도 성과연봉이 판공비나 복지비용으로서 성격을 지닌다고 볼만한 규정이 없는 점,

④ 피고가 성과연봉제가 도입되기 이전에 '선택적복지비' 항목의 돈을 피고의 근로자들에게 지급하였을 때에는 근로자들이 선택적복지비 항목에 관련한 비용을 실제 지출하였다는 사실을 확인하기 위하여 근로자들로부터 영수증 등 증빙서류를 제출받았으나, 피고가 현재 원고들을 포함한 피고의 근로자들에게 성과연봉을 지급할 때에는 선택적복지비 관련 비용 지출과 관련한 영수증 등 증빙서류를 근로자들로부터 제출받지는 않는 것으로 보이는 점,

⑤ 성과연봉이 달리 은혜적 금품에 불과하거나 근로자의 특수하고 우연한 사정에 의해 좌우되는 우발적·일시적 급여라고 볼 만한 자료가 없는 점

대법원도 경영평가성과급의 평균임금성을 인정한 원심의 판단을 그대로 수긍하였다.

4) 대법원 2016다239680 판결: 임금성(평균임금성) 인정

피고는 주택도시보증공사이고, 원고들은 피고 소속 근로자로 근무하다가 퇴직하였다. 쟁점은 피고가 지급한 경영평가성과급이 평균임금에 해당하는지 여부이다. 사실관계는 다음과 같다.

① 피고는 2010년 이전부터 경영평가성과급을 지급하여 왔는데, 경영평가성과급은 근로자들의 전년도 근무성적을 평가하여 지급 당해 연도에 매년 2회 기본급 또는 기본연봉의 2011년까지는 500%가, 2012년부터는 최대 250%까지 지급되어 왔다.

② 피고의 보수규정 제30조의3은 ‘사장은 경영실적평가 결과에 따라 경영평가성과급을 지급하고, 그 차등지급 기준 등은 사장이 따로 정하는 바에 의한다.’고 규정하고 있고, 연봉제규정 제23조는 ‘경영평가성과급은 종합근무평정규정 제14조에 의거 산출된 등급에 따라 차등지급하고, 차등지급 기준은 상임이사회에서 정한다.’고 규정하고 있다.

③ 공공기관운영법 제48조 제1항은 기획재정부장관이 공기업·준정부기관의 경영실적을 평가하도록 정하였다. 정부는 ‘공기업·준정부기관 예산집행지침’으로 경영평가성과급의 지급횟수, 차등 등급 수, 등급별 인원 비율, 차등수준 등의 지급기준을 마련해 왔고, 공공기관운영법에 의한 경영실적평가 결과에 따라 피고에 적용되는 성과급 지급률을 정하였다.

④ 피고는 위와 같이 매년 정부가 정한 성과급 지급률을 기초로 보수규정, 연봉제규정, 상임이사회에서 정한 기준과 계산방식에 따라 잔여 성과상여금을 산정하여 소속 직원들에게 지급하였다.

원심(서울고등법원 2016. 6. 29. 선고 2015나2054828 판결)은 다음과 같이 판시하면서 경영평가성과급의 평균임금성을 인정하였다.

(피고는) 위 경영평가성과급은 근로자 개인의 근무에 대한 평가가 아니라 정부가 각 공공기관의 경영목표 및 경영실적, 기관장 경영계획서를 평가하여 그 결과에 따라 지급률이 결정되는 것으로서 근로자 개인의 소정근로의 대가로 볼 수 없으니 평균임금에 포함시켜서는 안 된다고 주장한다. 그러나 경영평가성과급이 보수규정에 의하여 피고에 지급의무가 지워져 있고, 피고의 모든 근로자 또는 일정한 요건에 해당하는 근로자에게 일률적으로 지급되어 왔음은 앞서 본 바와 같거나 앞서 든 증거들에 의하여 인정할 수 있으므로 이는 소정근로의 대가로서 평균임금에 해당한다고 할 것이다.

대법원도 경영평가성과급의 평균임금성을 인정한 원심의 판단을 그대로 수긍하였다.

2. 선행판례의 타당성 검토

가. 공기업 집단성과상여금

공기업 집단성과상여금에 대하여 (평균)임금성을 인정한 판결들에는 다음과 같은 특징이 있다. ① 대법원이 최초로 집단성과상여금의 평균임금성을 정면으로 인정하였다.⁶³⁾ ② 지급기준(지급대상, 지급조건)이 정해져 있다는 사정만으로 평균임금성을 인정함으로써 평균임금성 판단 기준을 완화하였다.⁶⁴⁾

1) 먼저 공기업 집단성과상여금이건 사기업 집단성과상여금이건 집단성과상여금이 근로의 대가로서 임금에 해당하는지가 검토되어야 한다.

학설은 대립한다. 집단성과상여금도 개인성과상여금과 마찬가지로 근로의 제공과 밀접한 관련이 있으므로 임금성을 인정해야 한다는 견해(긍정설, 다수설)⁶⁵⁾와 개인성과상여금과 달리 근로의 제공과 밀접한 관련이 없으므로 임금성을 부정해야 한다는 견해(부정설, 소수설)⁶⁶⁾가 그것이다. 부정설의 논거를 구체적으로 보면, 근로자가 통제할 수 없는 불확정적·외부적 요인인 지급기준, 지급조건에 따라 지급되는 금원은 임금성을 부정하여야 한다거나,⁶⁷⁾ 경영성과 창출에 근로자가 기여하는 부분이 있다는 사정만으로 근로제공과의 밀접성을 인정할 수 없다거나,⁶⁸⁾ 경영성과는 경영자의 경영전략, 시장상황 등 근로자가 제공한 근로와 무관한 다수의 요인이 결합한 결과이므로 근로제공과 직접적 관련성이 없다고 한다.⁶⁹⁾

다음과 같은 이유로 긍정설이 타당하다.

① 경영성과란 회사 경영진의 경영능력, 회사 자본이나 자산의 기여, 협업에 의한 근로자들의 근로제공 등이 총체적으로 결합하여 이루어진 것이다. 그래서 회사는 경영성과를 경영진에 대한 보수, 주주에 대한 배당, 근로자들에 대한 성과상여 등으로 배분한다. 즉 근로자들이 받는 집단성과상여금은 근로자들이 제공한 협업 근로가 경영성과에서 차지한 가치를 평가하여 그 몫을 지급하는 것이므로 근로

63) 사기업 집단성과상여금의 임금성을 인정한 것으로 대법원 2011다42324 판결이 있으나 평균임금성을 인정한 것은 아니었다.

64) 문종철(주 29), 255; 심재진(주 4), 113.

65) 강성태(주 53), 50~51; 권오성(주 4), 67; 김태욱(주 17), 220; 문종철(주 29), 257~258; 심재진(주 4), 113; 유성재(주 4), 33.

66) 박지순·이진규(주 4), 199; 이정현, “공공기관 경영평가성과급의 임금성 여부”, 노동법률 통권 343호, 중앙경제사(2019), 37; 정종철(주 4), 113.

67) 정종철(주 4), 113.

68) 박지순·이진규(주 4), 199.

69) 이정현(주 66), 37.

의 양이나 질과 밀접한 관련이 있다고 평가되어야 한다.⁷⁰⁾

② 근로자가 자신이 개인적으로 이룬 성과에 대하여 그 대가를 지급받는 것(개인성과상여금)이나 근로자집단이 이룬 성과 중 개인의 몫을 안분하여 그 대가를 지급받는 것(집단성과상여금)이나 결국 근로자가 제공한 근로에 대한 대가라는 점에서 그 본질을 같이 한다.

③ 만일 경영성과가 근로자의 근로제공과 전혀 무관하다면 이를 배분하는 회사의 대표이사는 경영진에 대한 보수, 주주에 대한 배당, 회사 유보 등으로 처리해야 할 부분을 임의로 근로자에게 배분함으로써 회사에 손해를 끼쳤으므로 회사 등을 피해자로 한 횡령이나 배임 등이 성립한다고 보아야 한다. 그러나 아무도 이와 같은 논리를 주장하지 않고 이와 같이 보지도 않는다. 또한 회사(사용자)는 이윤을 추구하는 사업자이지 자선사업가가 아니므로 근로자가 제공한 근로에 대한 대가가 아니라면 집단성과상여금을 근로자에게 지급할 특별한 이유나 동기가 없다.

④ 근로자 개인의 실적 역시 근로자가 통제할 수 없는 불확정적이고 외부적 요인에 의하여 영향을 받을 수 있다. 그럼에도 개인성과상여금의 임금성을 인정함이 판례(대법원 2001다76328 판결 등 일부 예외적인 판결 제외)와 통설의 입장이다. 근로자가 통제할 수 없는 불확정적이고 외부적 요인에 의하여 영향을 받을 수 있다고 하여 근로자가 제공한 근로의 성과에 대하여 그 몫으로 받는 것이 왜 근로의 대가가 아닌 것으로 되어야 하는지 분명한 논거도 없다. 또한 경영성과 창출에 근로자의 기여 부분 외에 다른 부분이 있다 하더라도, 여러 기여 부분 중 근로자 자신의 기여 부분에 대한 대가를 근로자가 받는 것이 왜 근로의 대가가 아닌 것으로 되는지에 대한 근거도 불분명하다.

공기업 집단성과상여금에 관한 선행판례들은 명시적으로 집단성과상여가 근로의 대가라고 판시하지는 않았지만 이를 당연히 전제로 하고 있어 긍정설(다수설)과 쉼을 같이 하고 있고 타당한 결론이라 할 것이다.

2) 앞서 살펴본 바와 같이 지급의 계속성, 정기성과 지급사유의 사전확정성은 평균임금에서 제외되는 임금 즉 임시로 지급된 임금 내지 임시적·돌발적 사유로

70) 원래 주주에게 분배해야 할 이익을 근로자에게 분여한 것인지, 근로자의 과거 근로에 대한 보상 또는 장래 생산성에 대한 유인에서 지급한 것인지라는 실질에 의하여 판단하여야 한다는 견해(권오성(주 4), 67)도 같은 취지로 이해된다.

지급되는 임금인지를 판단하는 자료이다. 그리고 지급의 계속성, 정기성과 지급사유의 사전확정성은 두 가지 모두를 갖추어야 평균임금으로 인정되는 것이 아니고 그중 어느 하나만 갖추더라도 임시로 지급된 임금이 아니므로 평균임금에 해당하는 것으로 보아야 함은 앞서 본 바와 같다. 공기업 집단성과상여금에 관한 선행판결들은, 최저지급률, 최저지급액이 정해져 있지 않고 매년 새로이 결정되므로 경영평가 결과에 따라 지급 여부나 지급액이 달라지더라도, 지급기준(지급대상, 지급조건)이 정해져 있는 이상 지급사유의 사전확정성을 널리 인정하였다는 점에서도 의의가 크다. 지급기준이 정해져 있는 이상 사용자가 임의로 지급하는 것이라고 볼 수 없어 평균임금성을 인정함이 마땅하고, 향후에도 그 지급을 예견할 수 있어 임시적·돌발적 사유로 지급되는 것으로 평가할 수는 없다 할 것이므로 이 부분 판단은 타당하다 할 것이다. 다만 어느 정도로 지급기준이 정해져 있어야 지급사유의 사전확정성이 인정되는지가 추가적으로 논의될 수 있을 것으로 보인다.

나. 사기업 집단성과상여금

1) 사기업 집단성과상여금에 관한 선행판례들은 대법원 2011다42324 판결을 제외하고는 임금성(평균임금성)을 모두 부정하였는데, 그 주된 근거로 지급사유의 사전확정성 및 지급의 계속성, 정기성이 없음을 들고 있다는 점이 가장 큰 특징이다. 즉 대법원 2012다48077 판결 외에는 집단성과가 상여금의 원천 내지 근거라는 점 자체를 임금성(평균임금성) 부정의 근거로 들고 있지는 않다는 점이다. 공기업 집단성과상여금과 비교해 보면, 사기업 집단성과상여금이나 공기업 집단성과상여금이나 상여금의 원천 내지 근거가 집단성과(경영성과)라는 점은 동일하고 집단성과상여금은 근로의 대가라 할 것이므로 공기업 집단성과상여금의 임금성을 인정하는 이상 사기업 집단성과상여금을 그 원천이나 근거가 집단성과임을 들어 임금성을 부정할 수는 없다. 더욱이, 공기업 집단성과상여금은 집단성과에 따라 상여금을 차등 지급한다는 점에서 사기업 집단성과상여금과 동일하지만, 사기업 집단성과상여금의 재원은 집단성과 그 자체인 반면에 공기업 집단성과상여금의 재원은 집단성과 그 자체가 아니라 세금이라는 점에서, 공기업 집단성과상여금은 사기업 집단성과상여금보다 근로자의 협업근로와의 관계가 더 멀다고 평가할 수 있다. 이런 점을 고려하더라도, 공기업 집단성과상여금의 임금성을 인정하면서 사기업

집단성과상여금의 임금성을 그 자체로 부정할 수는 없다.

2) 결국 지급사유와 사전확정성 및 지급의 계속성, 정기성으로 임금성 및 평균임금성을 판단하는 것이 타당한지, 나아가 어떻게 판단해야 하는지가 문제 된다.

먼저, 지급사유와 사전확정성 및 지급의 계속성, 정기성은 임금성 요건이 아니라 평균임금성을 징표하는 자료일 뿐이므로 지급사유와 사전확정성 및 지급의 계속성, 정기성이 없다고 임금성을 부정할 수는 없다. 그런 점에서 보면 사기업 집단성과상여금에 대한 선행판결들은 임금성과 평균임금성을 혼동하고 있다는 비판을 면하기 어렵다.

다음으로, 평균임금성과 관련하여, 사기업 집단성과상여금에 대한 선행판결들 중 일부는 공기업 집단성과상여금에 대한 선행판결들보다 지급사유와 사전확정성과 지급의 계속성, 정기성을 훨씬 엄격하게 판단하고 있음을 지적하지 않을 수 없다.

대법원 97다18936 판결을 보면, 근로자가 퇴직한 1995. 4. 22.을 기준으로 1994. 7.에 단 한 차례 특별성과상여금이 지급되었고, 그것도 근로를 제공한 이후 1994. 7.에 임금협정을 체결하면서 그 무렵 지급된 것이므로, 지급의 계속성, 정기성과 지급사유와 사전확정성이 없다는 이유로 평균임금성을 부정한 대법원의 판단을 수긍할 수 있다.

대법원 2001다16722 판결 또한 특별성과급에 대한 지급의무를 근거지을 근로계약, 단체협약, 취업규칙 등이 미리 정해져 있었다는 점에 대한 아무런 자료가 없어 지급사유와 사전확정성이 없다고 볼 수 있고, 근로자 재직기간 중 단 한 차례 지급되었다는 것만으로 지급의 계속성, 정기성을 인정할 수도 없으므로, 지급의 계속성, 정기성과 지급사유와 사전확정성이 없다는 이유로 평균임금성을 부정한 대법원의 판단을 역시 수긍할 수 있다.

그러나 대법원 2003다54322, 54339 판결은 1992년부터 1996년까지 매년 임금협약을 통해 경영성과금을 지급해 왔으므로 지급의 계속성, 정기성이 인정됨이 분명하고, 구체적인 지급액이나 지급기준이 임금협약에서 정해져 있으므로 지급사유와 사전확정성도 인정되는 것으로 보임에도 평균임금성을 부정하였다는 점에서 그 타당성에 의문이 있다(설령 지급사유와 사전확정성을 부정하더라도, 지급의

계속성, 정기성이 있는 이상 임시로 지급되는 우발적 임금이라고 볼 수는 없으므로 평균임금성을 인정함이 타당하다).⁷¹⁾ 물론 무분규 조건이 있었다는 점에서 논의의 여지가 있는 데 이 부분은 후술한다.

대법원 2012다48077 판결 역시 원고는 퇴직 직전까지 4년 동안 계속하여 LTI 명목의 성과급을 지급받았으므로 지급의 계속성, 정기성이 인정되므로 평균임금성을 인정함이 타당함에도 평균임금성을 부정하였다. 특히 이 판결은 집단적 경영성과 자체를 근로자 개인의 업무실적 및 근로의 제공과 무관한 것으로 평가하고 있다는 점에서 공기업 집단성과상여금에 관한 선행판례들과 명백히 배치된다고 볼 수 있고, 집단적 경영성과에 대하여 근로 대가성을 인정하여야 한다는 앞선 검토와도 배치되므로 그 타당성에는 의문이 크다.

3) 무분규라는 것은 노동의 제공으로 얻어지는 성과가 아니므로 분규를 자제한 성과를 근로의 대상으로 볼 수는 없다는 이유로 무분규 조건 경영성과급의 임금성을 부정한 대법원 2003다54322, 54339 판결에 찬성하는 견해⁷²⁾는 다음과 같은 이유로 찬성하기 어렵다.

근로계약에서 임금 지급에 조건이 붙는 경우는 다양하다. 그 지급에 조건이 붙어 있다고 하더라도 근로의 대가로 지급되는 것이고 지급의무의 정함이 있으면 임금이라고 보아야 하지, 조건의 성취가 근로의 제공으로 얻어지는 성과인지 여부에 따라 임금성 여부를 판단하여서는 안 될 것이다.

무분규 조건의 경영성과급 역시 앞서 검토한 바와 같이, 경영성과급 자체는 근로의 대가에 해당하고 단체협약 등에 의하여 지급의무가 있는 이상 경영성과급의 임금성을 인정함이 타당할 것으로 생각한다.

4) 공기업 집단성과상여금에 대한 선행판례들 이후에 사기업 집단성과상여금의 (평균)임금성을 판단한 판결인 수원지방법원 여주지원 2019가단50590 판결⁷³⁾에 대하여 약간의 언급을 하고자 한다.

71) 매년 당해 연도의 임금협약에서 지급조건, 지급률 등을 정하고서 시행된다면 임시로 지급된다고 볼 수는 없으므로 평균임금에서 배제되어서는 안 된다면서 위 판결을 비판한 견해로는, 김홍영(주 28), 79.

72) 김홍영(주 28), 77.

73) 수원지법 2021. 2. 4. 선고 2020나55510 판결로 항소기각되었다(2021. 2. 19. 현재 상고제기기간 중임).

위 판결 사안을 보면, 피고이자 사용자인 회사는 1999년부터 원고들이 퇴직한 2016년까지 17년간 매년 5, 6월경 노사합의로 경영평가성과급을 지급해 왔고, 연봉제 급여규칙, 취업규칙, 단체협약 등에 상여금을 임금의 일종으로 정하면서 추상적으로 회사는 상여금을 지급할 수 있다고 규정하고 있다. 다만 구체적인 지급기준을 미리 정하고 있다고 볼 만한 자료는 보이지 않는다.

먼저 경영평가성과급은 근로의 대가이고 취업규칙과 단체협약, 노사합의로 지급한 것이므로 근로계약 등에 의한 지급의무도 인정된다고 할 것이어서 임금에 해당한다 할 것이다.

다음으로 17년간 계속적, 정기적으로 지급해 왔으므로 임시로 지급되는 임금 내지 우발적 사유로 지급되는 임금이라고 볼 수는 없어 평균임금성 또한 인정되어야 할 것이다(지급기준의 사전확정성이 인정되는지에 관하여는 양론의 여지가 있어 보인다). 경영평가성과급의 평균임금성을 부정한 수원지방법원 여주지원 2019 가단50590 판결의 타당성에는 의문이 있다.

V. 결론

1. 선행판례의 불일치와 성과상여금의 임금성

성과상여금의 (평균)임금성에 대한 선행판례들을 보면 선행판례 법리가 일관된다고 볼 수 없고 오히려 서로 모순되는 측면이 있음을 지적하지 않을 수 없다.

개인성과상여금의 임금성을 부정한 대법원 2001다76328 판결은 임금성을 인정한 주류적 판례들과 명백히 충돌하는 것으로 그 타당성에는 의문이 있다. 개인성과상여금은 그 자체로 근로의 대가이므로 임금성을 인정하여야 할 것이다.

사기업 집단성과상여금에 대한 판결들 중 임금성을 인정한 대법원 2012다48077 판결은 임금성을 부정한 주류적 판례들과 충돌하는 것으로 보이고, 임금성을 부정한 판결들도 대체로는 지급의 계속성, 정기성과 지급사유의 사전확정성을 근거로 임금성을 판단했지만, 대법원 2012다48077 판결은 집단성과상여 그 자체의 근로 대가성을 부정함을 근거로 임금성을 판단한 것이어서 그 논거가 통일되어 있다고 볼 수도 없다. 더욱이 공기업 집단성과상여금에 대한 판결들은 집단성과상여금 그 자체의 근로 대가성이 인정됨을 전제로 한 판결들로 이해할 수 있으므로 그 점에

서 보면 대법원 2012다48077 판결은 공기업 집단성과상여금에 관한 선행판례들과 충돌한다. 집단성과상여금 역시 집단성과(경영성과) 중 근로자들의 협업근로가 기여한 몫을 평가하여 개별 근로자들에게 안분한 것이므로 개별성과상여금과 마찬가지로 근로의 대가성을 인정하여야 할 것이다.

그러므로 대법원은 향후 성과상여금의 임금성을 둘러싸고 이와 같은 선행판례들의 불일치를 정리할 필요가 있다고 생각한다.

2. 임금과 평균임금의 준별과 성과상여금의 평균임금성

성과상여금의 (평균)임금성을 둘러싼 판결들에서 나타나는 중요한 문제점은 임금성과 평균임금성을 준별하지 않고 있다는 점이다.⁷⁴⁾

문제 되는 항목이 근로의 대가인지, 근로계약 등에 의한 지급의무가 인정되는지 두 가지 기준만으로 임금성 여부를 판단하여야 한다. 지급의 계속성, 정기성이나 지급사유의 사전확정성은 임금 요건이 아니다. 실무상 임금성이 문제 되는 사안으로는, 부당해고로 인한 임금청구 또는 임금 상당 손해배상청구 사안, 불합리한 차별로 인한 임금차액청구 사안 또는 차액 상당 손해배상청구 사안 등을 들 수 있다.

평균임금성을 판단할 때에는 임시로 지급되는 임금 내지 우발적 사유로 지급되는 임금은 평균임금에서 제외되어야 한다. 그런데 임시로 지급되는 임금인지를 판단하는 중요한 기준이 지급의 계속성, 정기성과 지급사유의 사전확정성이다. 지급의 계속성, 정기성과 지급사유의 사전확정성 모두가 있어야 평균임금이고 어느 하나만 부정되면 임시로 지급되는 임금에 해당한다고 볼 것은 아니다. 지급의 계속성, 정기성과 지급사유의 사전확정성 모두가 부정되는 경우여야 임시로 지급되는 임금으로서 평균임금에서 제외된다 할 것이다.

나아가 평균임금성을 판단하는 요소인 지급사유의 사전확정성 관련해서도, 공기업 집단성과상여금에 관한 선행판례들은 지급액, 지급여부가 모두 확정되어 있어야 하는 것은 아니고 지급기준만 확정되어 있으면 됨을 명시하고 있다. 공기업 집단성과상여금에 관한 선행판례의 기준에 따라 실무가 확립되어야 할 것이다.

74) 평균임금성 요건(판단기준)으로 임금성을 판단해서는 안 된다는 의미이지, 평균임금성을 판단할 때 항상 임금성 여부를 먼저 검토하고 판시하여야 한다는 의미는 아니다.

<참고문헌>

- 김유성, 노동법 I - 개별적 근로관계법, 법문사(2005).
- 김형배, 노동법 26판, 박영사(2018).
- 노동법실무연구회(최은배 집필 부분), 근로기준법 주해 I 2판, 박영사(2020).
- 이상윤, 노동법 16판, 법문사(2019).
- 임종률, 노동법 17판, 박영사(2019).
- 하갑래, 근로기준법, 중앙경제사(2019).
- 하경효, 임금법제론, 신조사(2013).
- 강기탁, “상품권 판매에 따른 개인포상금이 퇴직금 산정의 기초가 되는 평균임금에 포함되는지 여부”, 노동판례 비평, 민주사회를 위한 변호사모임(2003).
- 강성태, “작업출장비와 특별성과상여금이 평균임금에 속하는가”, 노동법률 통권 84호, 노동판례연구회(1999).
- 권오성, “경영 성과급의 임금성”, 노동법률 통권 346호, 중앙경제사(2020).
- 기영석, “성과급의 임금성에 관한 고찰”, 노동법률 통권 299호, 중앙경제사(2016).
- 김기선, “개인 실적에 따라 지급되는 성과급의 임금성”, 노동법률 통권 280호, 중앙경제사(2014).
- 김태욱, “개인실적에 따라 지급되는 성과급의 임금성”, 노동판례 비평, 민주사회를 위한 변호사모임(2012).
- 김홍영, “근로자 개인의 실적에 따라 결정되는 성과급 상여금의 임금성 여부”, 노동법률 158호, 중앙경제사(2004).
- _____, “상여금의 임금성 여부”, 노동법연구 21호, 서울대학교 노동법연구회(2006).
- 문종철, “성과급 또는 상여금의 임금성에 관하여”, 우리법연구회 논문집 6집, 우리법연구회(2010).
- 박지순·이진규, “경영성과급의 임금성에 관한 연구”, 노동법논총 49집, 한국비교법학회(2020).
- 심재진, “공공기관 경영평가성과급의 임금성”, 산업관계연구 29권 3호, 한국고용노사관계학회(2019).

- 유성재, “경영평가성과급의 임금성”, 노동법률 통권 343호, 중앙경제사(2019).
- 이 정, “상여금(경영성과급)의 법적 성격에 관한 연구 - 일본과의 비교법적 고찰을 중심으로”, 외법논집 44권 2호, 법학연구소(2020).
- 이정현, “공공기관 경영평가성과급의 임금성 여부”, 노동법률 통권 343호, 중앙경제사(2019).
- 이철수, “현행 임금제도의 비판적 검토”, 노동법연구 12호, 서울대학교 노동법연구회(2002).
- 정종철, “변동성과급은 평균임금에 포함되어야 하는가?”, 노동법률 통권 340호, 중앙경제사(2019).
- 조영선, “성과급이 근로기준법상 임금에 해당하는지”, 노동관계 비평, 민주사회를 위한 변호사모임(2005).

菅野和夫, 労働法 十一版補正版, 弘文堂(2017).

荒木尚志, 労働法 三版, 有斐閣(2016).

〈Abstract〉

Whether Performance Bonus Constitutes (Average) Wages

Lim Sang-min

After the Korean Supreme Court recently rendered decisions that collective performance bonus (payment for business performance) of public enterprise corresponds to average wages, debates over the issue of whether collective performance bonus (payment for business performance) of private companies can also be recognized as average wages have flourished.

In reviewing the precedents dealing with the issue of whether a performance bonus paid by employer to employee has the nature of wages, some problems can be seen in these decisions. Namely, they did not distinguish between wages and average wages. The only requirements for performance bonus to satisfy to constitute as wages are that ① they should be provided as remuneration for work, and ② payment obligation should be based on labor contract, etc. Factors of continuity and regularity of payment or confirmation of the ground for payment, which the Court has placed emphasis on, are standards applied in determining whether certain wages are paid on a temporary basis. If wages are paid on a temporary basis, they are not included in average wages.

The mainstream view held by the precedents recognizes the wages nature of personal performance bonus, which, in my view, is reasonable. The precedents which have admitted the average wages nature of collective performance bonus of public enterprise presuppose that collective performance bonus is paid as remuneration for work. Then, it is rational to find that collective performance bonus of private companies also corresponds to wages as remuneration for

work.

Even if the wage nature of collective performance bonus of private companies is admitted, the issue of whether such bonus corresponds to average wages should also be considered. We should review the relationship between ① continuity and regularity of payment and ② confirmation of the ground for payment, which are the standards for determining the nature of average wages. In case either one of the two standards is admitted, performance bonus cannot be considered to have been paid on a temporary basis and, therefore, collective performance bonus of private companies should be found to corresponds not only to wages but to average wages.

Keywords: wages, average wages, wages paid on a temporary basis, remuneration for work, payment obligation, continuity and regularity of payment, confirmation of the ground for payment, performance bonus, personal performance bonus, collective performance bonus, payment for business performance, employee, employer etc.